

# 개정 노조법 제2조 제2호 시행의 쟁점과 과제\* \*\*

— 실질적 지배력의 판단기준과 창구단일화 절차의  
적용 문제를 중심으로 —

김 린\*\*\*

## 목 차

- I. 들어가며
- II. 사용자성 판단: 실질적 지배력
- III. 교섭창구단일화 절차 적용 여부
- IV. 새로운 교섭 질서 구축을 위한 노사정의 과제
- V. 나가며

## I. 들어가며

대형마트에서 구매한 냉장고의 결함으로 피해가 발생한 경우, 누구에게 책임을 묻는가? 설마, 매매계약의 직접 상대방인 ‘대형마트’인가? 아니다. 제품의 설계, 제조, 나아가 안전과 품질을 실질적으로 지배·결정한

투고일 2025. 11. 20., 심사일 2025. 12. 5., 게재확정일 2025. 12. 12.

\* 이 논문은 인하대학교의 지원에 의해 연구되었다.

\*\* 이 글은 한국고용노사관계학회가 2025. 10. 30. 개최한 “노동조합법 제2조 개정과 단체교섭의 새로운 지평-·노란봉투법 이후의 과제-” 정책토론회에서 필자가 발제한 “개정 노동조합법 제2조 시행의 쟁점과 과제—실질적 지배력, 입증책임, 교섭절차를 중심으로 —”의 내용을 수정하여 논문 형식으로 작성한 것이다. 이 발제 및 논문 작성·심사 과정에서 고견을 주신 여러 연구자 및 실무자들에게 깊은 감사의 말씀을 올린다.

\*\*\* 인하대학교 법학전문대학원 교수

주체인 ‘제조업자’에게 책임을 묻는 것이 우리의 상식이다. 이러한 상식을 법제화한 것이 바로 「제조물책임법」이다. 제조물책임법은 형식적인 계약관계를 넘어 제품 생산을 실질적 통제함으로써 문제해결력을 보유한 제조업자에게 책임을 부과한다는데 그 핵심이 있다.<sup>1)</sup> 이 법은 “실질적 권한이 있는 곳에 책임이 있다”는 대원칙을 확인해 정보 비대칭 하의 소비자를 보호하고 피해를 실질적으로 구제한다는 점에서 지극히 합리적이다. 기실 계약의 직접 상대방이 아닌 ‘실질적 권한자’에게 책임을 묻는 법리는 이미 우리 사회에 깊숙이 자리 잡고 있는 셈이다.

최근 개정된 「노동조합및노동관계조정법」(이하 “노조법”이라 한다) 제2조 제2호 후문을 둘러싼 논란 역시 이와 동일한 맥락에서 바라보아야 한다. 개정법은 ‘계약관계의 배타성’이라는 원칙을 폐기하려는 것이 아니라, 노동 현장의 ‘실질’을 반영하려는 데 그 핵심이 있다.

현대 산업 현장에서 하청 근로자는 형식적으로 하청업체와 근로계약을 체결하지만, 그들의 임금, 업무강도 등 주요 근로조건은 임금의 재원이 될 도급비나 생산목표 설정 내지 생산계획 할당과 같이 그의 계약관계에서는 보이지 않는 그 누군가의 의사결정에 의해 실질적으로 좌우되는 경우가 빈번하다.

개정법은 바로 이러한 현실의 괴리를 직시하여 “근로계약 체결 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자” 역시 그 범위 내에서 사용자로 보도록 명문화하였다. 이는 제조물 책임의 법리와 마찬가지로, 형식적 계약관계 뒤에 숨어 실질적 지배력을 행사하는 주체에게 헌법상 단체교섭권의 상대방으로서의 교섭의무 내지 교섭책임을 부과하는 것이다. 결국 이 개정은 노동관계 영역에서도 ‘실질적 권한(지배력)’이 있는 곳에 책임(교섭 의무)이 있다’는 상식을 법 원칙으로 실질화하려는 입법적 시도라 평가할 수 있다.

이 글은 이러한 개정 노조법 제2조의 원활한 시행과 실무 정착을 위하여 제기되는 쟁점을 검토하는 것을 목적으로 한다. 구체적으로, ‘실질적 지배력’을 판단하는 객관적이고 예측 가능한 기준은 무엇인지 및 원하청

1) 윤진수, 『민법논고 VI』, 박영사, 2015, 420쪽.

교섭 시 ‘교섭창구단일화’ 절차는 어떻게 적용되어야 하는지를 실무적 관점에서 분석하고, 새로운 교섭 질서 구축을 위한 노사정의 과제를 제언하고자 한다.

## II. 사용자성 판단: 실질적 지배력

### 1. 새로운 사용자 개념의 입법 취지

개정전 노조법 제2조 제2호는 사용자를 “사업주, 사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자”라고만 정의하였다. 그러나 개정법은 여기에 “이 경우 근로계약 체결 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자도 그 범위에 있어서는 사용자로 본다.”는 문구를 후문에 추가하였다. 이는 노동 현장의 다층적 고용 구조 현실을 반영하여 전통적인 사용자 개념을 확대한 것이다. 즉, ‘근로계약 관계’의 존재라는 형식을 넘어, 근로계약 관계가 없는 제3자라 할지라도 근로자의 근로조건에 실질적인 권한을 행사하면 그에게 단체교섭의 책임을 부과한다. 이렇게 함으로써 구조적으로 열악한 지위에 있는 근로자의 헌법상 단체교섭권을 실질적으로 보장하려는 데 그 목적이 있다.

그러나 이러한 입법취지에도 불구하고 개정법을 시행함에 있어서는 법 해석과 실무 적용과 관련하여 논란이 있다. 즉, 개정법의 실효성과 현장 수용성은 결국 “실질적이고 구체적인 지배·결정”이라는 요건의 의미를 얼마나 객관적이고 예측가능하게 해석하는지가 문제된다. 만약 이 기준이 모호하여 자의적으로 해석되거나, 혹은 반대로 종래 원하청관계에서 치열하게 다투어왔던 전통적인 ‘불법파견’의 징표와 혼동되어 엄격하게 적용된다면 입법 취지가 물각될 위험이 있다. 이에 본장에서는 ‘실질적 지배력’을 판단하기 위한 합리적 해석 기준을 모색해 본다.

## 2. 개정전 노조법 하에서의 사법적 논의

개정 노조법 제2조 제2호 후문은 입법적 공백 상태에서 새롭게 창설된 규정이 아니다. 이는 이미 노동 현장의 다층적 고용 구조 심화에 따라, 사법부와 노동위원회가 기존 법체계 내에서 이른바 ‘진짜 사장’의 교섭 책임을 인정하기 위해 고심해 온 법리가 입법적으로 확인되고 명문화된 결과라 할 수 있다. 그리고 이러한 사법적 판단에는 외국의 사례 역시 중요한 참고가 되었다.<sup>2)</sup> 따라서 ‘실질적 지배력’에 관한 해석기준을 정립을 위한 시도는 사법적 판단 사례를 살펴보는 것에서부터 시작

---

2) 예컨대, 사용자 개념의 확대는 국내의 특수한 현상만은 아니다. 산업구조의 변화는 어느나라에서건 문제될 수 있는 현상이며, 각국은 이러한 변화에 대응하여 노동법 적용의 패러다임을 자신의 여건에 맞게 수정하고 있다. 미국의 경우, 2015년 연방노동관계위원회(NLRB)의 Browning-Ferris 결정(Browning-Ferris Industries, 362 NLRB No. 186 (2015))은 공동사용자(joint employer) 법리의 전환점이 되었다. 기존에 ‘직접적이고 즉각적인(direct and immediate)’ 통제를 행사해야만 공동사용자로 인정했던 엄격한 기준을 완화하여, 원청이 하청 근로자의 근로조건에 대해 ‘유보된(reserved)’ 통제권을 갖거나 ‘간접적인(indirect)’ 통제를 행사하는 것만으로도 공동사용자로서의 단체교섭 의무를 질 수 있다고 판단기준을 확대한 것이다. 이는 복잡한 균열일터 구조에 숨은 원청의 실질적 지배력을 포착하려는 시도라 할 수 있다. 이후 집권 세력의 교체로 이 법리는 현재 적용되고 있지는 않지만 여전히 부활의 여지가 있으므로 주목할 필요는 있다(이 결정의 부침과 바이트 정부 시절까지의 동향과 이를 둘러싼 국내 논쟁의 전개에 대해서는 이태현, “미국 공동사용자 법리의 현황과 시사점 - 브라우닝 펠리스 결정과 그 이후의 전개를 중심으로 -”, 『노동법학』 제86호, 한국노동법학회, 2023, 105-109쪽 참조. 2024년 기준으로 이 결정의 법리는 적용되고 있지 않은 상태이다.)

한편, 일본의 경우에도, 최고재판소가 아사히방송 사건을 통해, 근로계약관계가 없는 원청(방송국)이라 할지라도 하청(외부 스태프) 근로자의 기본적인 근로조건을 실질적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있다면, 노동조합 법상 단체교섭의 상대방으로서의 지위를 인정할 수 있음을 확인한 바 있다(이 판결 및 그 후 일본에서의 논의에 대한 소개는 고수현, “아사히방송 판결 그후”, 『법학논총』 제40집 제4호, 한양대학교 법학연구소, 2023 참조). 대법원의 현대중공업 판결이 이에 영향을 받았다고 평가되고 있다(강성태, “사내하도급 삼부작 판결의 의의”, 『노동법학』 제35호, 한국노동법학회, 2010, 29-30쪽 참조).

한다. 개정전 노조법이 적용된 사안에서 원청의 사용자성을 인정한 사법적 논의는 크게 두 가지 접근 방식으로 전개되어 왔다.

### 1) ‘실질적 지배력’ 원칙의 확립과 사실관계 중심의 접근

그 법리의 출발점은 대법원 2010. 3. 25. 선고 2007두8881 판결(이하 “현대중공업 판결”이라 한다)이다.<sup>3)</sup> 이 판결은 비록 단체교섭 거부가 아닌 지배·개입의 부당노동행위(구 노조법 제81조 제4호) 구제신청 사건이었으나, “근로자의 기본적인 노동조건 등에 관하여 그 근로자를 고용한 사업주로서의 권한과 책임을 일정 부분 담당하고 있다고 볼 정도로 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자”라면 노조법상 사용자에게 해당한다고 판시하였다. 이는 근로계약의 형식을 넘어 ‘실질적 지배력’을 기준으로 노조법상 사용자성을 판단한 최초의 대법원 판결이라는 점에서 의미가 있다. 다만 이 판결에서는 실질적 지배력을 판단하기 위한 기준을 구체적으로 제시하지는 않았다. 대신 ‘실질적이고 구체적인 지배·결정’이라는 대원칙을 천명한 후, 원청이 하청 근로자의 작업 배치, 징계 등에 관여한 구체적인 사실관계를 나열하고 이를 종합적으로 평가하여 원청이 사용자이다 라는 결론을 도출하는 방식을 취했다.<sup>4)</sup>

법원의 이러한 사실관계 중심의 종합적 판단 방식은 서울고등법원 2023. 1. 20. 선고 2021누35969 판결(이하 “CJ대한통운 판결”이라 한다)에서도 이어졌는데, 법원은 구체적 기준을 제시하기보다는 고려요소를 제시하면서<sup>5)</sup> 각 교섭의제별로 지배력 인정에 관한 사실관계를 적시하거

3) 이 판결의 의미를 사내하도급관계에서 발생한 노동법적 문제와 연결하여 분석한 문헌으로 강성태, 앞의 논문, 19쪽 이하 참조.

4) 현대중공업 판결의 법리가 단체교섭 과정에서 본격적으로 거론되기까지는 오랜 시간이 걸렸지만, 그 사이의 기간 동안 하급심에서 실질적 지배력설을 채택한 판결이 몇 건 등장하기도 하였는데, 이에 대한 소개는 김민기, 『사내하청에 대한 노동법적 규율 - 단체교섭권의 실현을 중심으로 -』, 서울대학교 법학박사 학위논문, 2023, 213쪽 이하 참조.

5) 1심인 서울행정법원 2023. 1. 12. 선고 2021구합71748 판결에서는 다음과 같은 정도를 제시하였고, 항소심도 이를 인용하였다. “노동조합법상 단체교

나, 지배력이 없다며 제시한 원청의 논거와 배치되는 사실관계를 인정하는 방식으로 실질적 지배력 유무를 판단하였다.<sup>67)</sup>

## 2) 판단 기준의 구체화 시도

이러한 사실관계 중심의 종합적 판단 기조는 최근 하급심에서 판단 기준 자체를 유형화하고 명시적으로 제시하려는 시도로 발전하였다.<sup>8)9)</sup>

---

섭 의무를 부담하는 사용자에게 해당하는지는 사업주가 근로조건인 교섭요구 사항에 대하여 실질적으로 결정하거나, 근로자가 해당 근로조건을 사업주의 의사대로 또는 정해진 대로 복종하여 따를 수밖에 없어 사업주가 해당 근로조건을 지배하고 있는지를 기준으로 판단해야 하고, 그러한 판단을 함에 있어서는 원고와 지배점의 관계, 지배점 택배기사의 업무가 상시적·필수적인 업무인지, 원고의 사업체계의 일부로 편입됨으로써 근로조건을 지배하거나 결정하는 원고의 지위가 지속적인지 등을 종합적으로 고려하여야 한다.”

- 6) CJ대한통운 판결 및 그 1심 판결 참조. 예컨대, 이 사건에서 법원은 쟁점이 된 ‘주 5일제 시행’이나 ‘급지(수수료) 인상’와 관련하여, 원청이 부속계약서를 통해 6일의 근무일과 배송 단가를 결정하면 지배점은 이를 수동적으로 따를 수밖에 없어 택배기사에게 변경하여 적용하는 것이 현실적으로 어렵다는 사실을 지배력 인정의 논거로 제시하였다. 이밖에도 ‘서브터미널 작업환경 개선’ 및 ‘분류작업 개선’ 의제에 대해서도, 원청이 서브터미널과 휠소터(자동분류기) 등 핵심 설비를 소유하고 있을 뿐만 아니라, 모바일 어플리케이션과 전산시스템을 통해 업무 전반을 관리·통제하고 있으며, 해당 사안은 원청이 구축한 유·무형의 택배시스템의 운영방식에 수정을 가하거나 원청이 마련한 위수탁계약의 내용, 매뉴얼, 지침 등의 변경을 필요로 하는 성격의 것이라는 등과 같이 구체적인 사실관계 및 그에 대한 직접적 평가를 근거로 원청의 실질적 지배력을 인정하였다.
- 7) 백화점면세점판매서비스노동조합이 제기한 사건에 대한 서울행정법원 2025. 10. 30. 선고 2024구합72896 판결도 이러한 부류에 속한다.
- 8) CJ대한통운 판결에서는 “노동조합법 제81조 제1항 제3호의 사용자에게 근로조건 등을 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자도 포함된다고 해석하더라도 법관의 보충적 해석에 따라 그 의미를 합리적으로 결정할 수 있고, 그 구체적 해석 기준은 선포의 집적을 통해서 발전시켜 나갈 수 있을뿐더러..”라고 하여 선포의 집적을 통해 장차 구체적 해석 기준이 제시될 것임을 시사하였다.
- 9) 중앙노동위원회의 판정을 통해서도 다양한 의견이 개진된 바 있으나, 이후 법원을 거치면서 판단의 내용이 더 깊고 세밀해지고 있으므로 검토의 편의

최근 선고된 서울행정법원 2025. 7. 25. 선고 2023구합55658·2023구합 56231(병합) 판결(이하 “한화오션 판결”이라 한다) 및 서울행정법원 2025. 7. 25. 선고 2022구합69230 판결(이하 “현대제철 판결”이라 한다)이 그러한 예라고 볼 수 있다. 이들 판결에서도 하청 노조의 단체교섭 요구를 원청이 거부한 행위가 부당노동행위에 해당하는지 여부가 쟁점이 되었는데, 이 사건들에서 법원은, 기존의 사실관계 나열 방식에서 나아가, 다음과 같이 원청의 사용자성(단체교섭 의무)을 판단하기 위한 구체적인 기준을 명시적으로 목록화하고 그 판단에 필요한 고려요소를 제시하였다.<sup>10)</sup> 그 내용은 다음과 같다.

“원고 회사가 사내하청업체 근로자에 대하여 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자에 해당하는지 여부는 ① 교섭 요구 의제에 대하여 원청이 실질적이고 구체적으로 지배·결정하는 지위에 있는지, ② 사내하청업체 근로자들의 노무가 원청의 사업 수행에 필수적이고 사업체계에 편입되어 있는지, ③ 사내하청업체 근로자들의 노동조건 등을 원청과의 단체교섭에 의해 집단적으로 결정할 필요성과 타당성이 있는지 여부 등을 기준으로 판단하여야 하고, 위와 같은 판단을 함에 있어 ④ 사내하청업체 근로자들의 업무가 이 사건 사업장에서 행하여지는 원고 회사의 사업에서 차지하는 비중, ⑤ 사내하청업

를 위해 이 글에서는 법원의 판결을 중심으로 검토한다. 노조법 개정 이전, 즉, 구 노조법만이 존재하던 상황을 전제로 중앙노동위원회 판정을 포함하여 법원 판결에서의 실질적 지배력의 판단기준의 변천을 검토한 최근의 문헌으로는 박수근·장영석, “원청사업주의 단체교섭의무와 실질적 지배력 판단기준 및 교섭사항”, 『노동법학』 92호, 한국노동법학회, 2024, 42쪽 이하 참조.

- 10) 법원이 한화오션 판결 등에서 인정한 이 판단기준의 원류를 거슬러 올라가면 CJ대한통운 사건에서의 중노위 판정문이 있다. 중노위 2021. 6. 2. 판정 중앙2021부노14에서 위와 동일한 취지의 기준을 제시한 바 있다. 중노위 판정의 기준에 대한 평가는 이승욱, “다면적 노무제공관계에서 부분적·중첩적 사용자성 - 중앙노동위원회 결정의 의의와 과제 -”, 『노동법학』 80호, 한국노동법학회, 2021, 122쪽 이하 참조. 이승욱 교수는 “중노위는 (1) 기준을 기본으로 하고, (2)기준과 (3)기준을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 하기때문에 이들 기준은 기준을 보강하는 요소로서의 성질을 가지는 것으로 파악하고 있는 것으로 보인다.”라고 평가하였다.

체 근로자의 근무방식과 이에 대한 원고 회사의 직·간접적 관여 정도, ㉔ 원고 회사와 사내하청업체의 관계, ㉕ 사내하청업체의 경제적 독립성 등을 종합적으로 고려하여야 한다”(한화오션 판결)<sup>11)</sup>

### 3) 소결: 입법적 확인과 남겨진 해석론의 과제

개정전 법제하에서 ‘실질적 지배력’의 해석은, 대법원의 현대중공업 판결에서 처음으로 사용자의 범위에 실질적 지배력이 있는 자를 포함하여, ‘사실관계 중심의 접근’을 통해 선례를 축적해 왔고, 비록 1심이기는 하나 최근 한화오션 판결 등에서는 판단기준의 구체화를 시도하는 수준까지 발전했다. 노조법 개정은 이러한 역사적 해석론 전개와 법제화를 향한 노력이 합쳐진 결과이다. 그러므로 개정법을 해석함에 있어서도 구법에 대한 법원의 기존 판결 사례는 중요한 참고자료가 된다. 특히, 한화오션 판결 및 현대제철 판결은 기준을 직접 제시하였다는 점에서 의미가 있다. 그러나 본격적인 논의에 앞서 분명히 해 둘 것이 있다. 바로 개정법의 해석이 이러한 판결례의 입장과 동일할 필요는 없다는 점이다. 개정법 시행을 앞둔 지금, 개정법 해석을 위한 구체적 판단기준을 정립하는 단계에서 기존의 판결례는 논의의 출발점으로 삼기에 좋은 자료일 뿐이다. 이러한 점을 염두에 두고 법원이 제시한 기준의 타당성을 검토하고 문제점을 살펴봄으로써 이를 더 발전시킨 개정법 상의 실질적 지배력에 관한 해석론을 모색해 보자.

### 3. 구법 해석론으로 법원이 제시한 판단 기준에 대한 검토

한화오션 및 현대제철 판결은 (1) 교섭 요구 의제에 대하여 원청이 실질적이고 구체적으로 지배·결정하는 지위에 있는지, (2) 사내하청업체 근로자들의 노무가 원청의 사업 수행에 필수적이고 사업체계에 편입되어 있는지, (3) 사내하청업체 근로자들의 노동조건 등을 원청과의 단계 교섭에 의해 집단적으로 결정할 필요성과 타당성이 있는지 여부(이하 각

11) 현대제철 판결에서는 ㉕를 언급하지는 않았다.



각 “기준(1)”, “기준(2)”, “기준(3)”이라 한다)를 명시적 기준으로 제시하였다는 점에서는 의미가 있지만, 이 기준을 개정 노조법 제2조 제2호의 해석론으로 곧바로 수용하기에는 다음과 같은 한계가 있다. 각 기준별로 살펴본다.

### 1) 기준(1)의 한계: 엄격 해석시 교섭 무력화의 위험

“교섭 요구 의제에 대하여 원청이 실질적이고 구체적으로 지배·결정하는 지위”라는 기준(1)은 그 자체로는 개정법의 문언인 “실질적이고 구체적으로 지배·결정”과 일치한다. 나아가 이 기준에서 사용한 ‘교섭 요구 의제에 대하여’라는 표현은 개정법의 “그 범위에 있어서는”이라는 문언에도 부합하는 듯이 보인다. 그런 점에서 기준(1)은 해석의 기준이 되어야 할 명제가 법문의 표현을 단순히 반복하는 것에 그쳐, 개정법 해석에 대해 구체적인 지침을 제공하지 못한다는 문제가 있다. 즉, ‘실질적 지배력’이 무엇인지 판단하기 위해 세운 기준이 다시 ‘실질적으로 지배하는지 살펴보라’는 식의 공허한 순환 논리에 갇히는 셈이다.

한편, 이는 법 조문 자체의 문제점을 동시에 내포하는 것이기도 하다. 현행 법문상 “그 범위에 있어서는”이라는 문구를 근거로 실질적 지배력 유무를 의제별로 판단해야 한다는 주장이 제기될 수 있다. 실제로 CJ대 한통운, 한화오션, 현대제철 판결에서는 각 의제별로 지배력 유무를 판단하는 검토가 이루어졌다. 기준(1) 역시 이러한 흐름에 부합한다고 볼 수 있다. 자칫 개별 교섭 안건 ‘별’로 원청의 지배력을 판단해야 한다는 해석이 극단화될 소지는 없는지 경계할 필요가 있다. 예를 들어 원청이 도급 단가를 통해 ‘임금’ 재원에 영향을 미쳤다면 오직 임금 교섭 의무만 부담하고, ‘근로시간’이나 ‘인력 충원’ 등 외견상 하청업체의 권한에 속하는 듯 보이는 사항에 대해서는 교섭 의무가 없다고 보는 것이 타당한지가 문제다.

그러나 근로조건이란 상호 유기적으로 연결된 경우가 많다. 임금 재원을 통제해 도급 단가를 낮게 책정하면 하청업체는 필연적으로 근로자에게 업무 강도를 높이거나 더 오래 근로할 것을 요구하는 식이다.<sup>12)</sup>

나아가 상호 연결된 근로조건을 의제별로 엄격히 분리하여 매 의제마다

다 원청의 구체적인 개입 사실을 현미경 검증하듯 요구한다면, 노동조합은 교섭 테이블에 앉기도 전에 자신이 요구할 모든 개별 의제에 대해 원청의 지배력을 각각 입증해야 하는 절차적 부담 지게 된다. 이는 필연적으로 본 교섭의 시작 전부터 “이번 의제가 원청의 지배력 범위에 속하는가?”를 둘러싼 끝없는 법적 다툼을 야기할 것이며, 단체교섭을 무력화하거나 지연시키는 수단으로 악용될 소지가 다분하다. 결과적으로 의제별 검토라는 기준을 극단화하면 ‘실질적인 교섭권 보장’이라는 노조법 개정 취지를 훼손할 정도로 교섭의 문턱을 높이는 결과를 초래할 수 있는 것이다. 따라서 의제별 접근이 아니라, 주요 근로조건을 중심으로 하는 포괄적 지배력 판단이 필요하다. 그런 점에서 노동위원회 교섭거부 부당노동행위 구제신청 사건에서는 교섭촉진의 관점에서 접근해 각 교섭의제별로 교섭거부의 당부를 판단하기보다 주요 의제에 대한 교섭의무가 인정되면 나머지 의제에 대해서는 평가를 생략하고 곧바로 교섭에 응하라는 단순한 주문을 낼 필요가 있을 것이다.<sup>13)</sup>

12) 낮은 화물운송 운임이 과로, 과적, 과속 운행의 원인이 된다는 점에 착안하여 화물자동차 운송 영역에서는 안전운임제가 도입된바 있다. 안전운임제의 도입배경과 해외사례에 대한 소개로는 김린, “화물자동차 안전운임제에 대한 법적 평가와 과제: 헌법상 적정임금 보장의 관점에서”, 『법학연구』 제28집 제3호, 인하대학교 법학연구소, 2025, 64-75쪽 참조.

13) 대법원은 부당노동행위 구제제도의 취지와 관련하여 “현실적으로 발생하는 부당노동행위의 유형은 다양하고, 노사관계의 변화에 따라 그 영향도 다각적이어서 그에 대응하는 부당노동행위 구제의 방법과 내용도 유연하고 탄력적일 필요가 있다. 노동조합법 제84조 또한 노동위원회가 전문적·합목적적 판단에 따라 개개 사건에 적절한 구제조치를 할 수 있도록 하기 위해, 부당노동행위가 성립한다고 판정한 때에는 사용자에게 구제명령을 발하여야 한다고 규정하고 있을 뿐 구제명령의 유형 및 내용에 관하여는 특별히 정하고 있지 아니하다(대법원 2018. 12. 27. 선고 2017두37031 판결, 대법원 2010. 3. 25. 선고 2007두8881 판결 등 참조)”라고 하므로, 노동위원회의 구제명령은 유연성을 발휘 할 수 있다. 한편, “노동위원회는 사용자로서 단체교섭의무가 있다는 점을 확인해주고 교섭에 응하라고 명령함으로써, 노사가 이를 수용한다면 정상적인 노사관계 질서로 회복할 수 있도록 한다. 노사 간에 최초의 교섭이 문제된 경우에는 정상적인 단체교섭질서를 형성한다는 의미를 갖는다. 단체교섭이 제대로 진행된 결과, 노사가 스스로 단체협약을 통한 자치를 실현한다면, 이로써 자주적인 노사관계 질서가 발전

## 2) 기준(2)의 문제점: ‘불법파견’ 법리와 불필요한 혼선

“하청 근로자의 노무가 원청 사업 수행에 필수적이고 사업체계에 편입되었는지 여부”를 묻는 기준(2)는, 대법원이 불법파견을 판단할 때 사용하는 핵심적인 지표, 즉 ‘원청 사업에의 실질적 편입’, ‘하청의 독립성 결여’ 등과 내용상 동일하거나 매우 유사하다.<sup>14)</sup> 불법파견에 있어서의 이러한 ‘인적 종속성’ 중심의 접근은 현대 기업의 고도화된 간접 통제 방식을 놓치는 한계가 있다. 교섭 의무를 부과하기 위한 기준은 ‘가짜 도급을 적발’하기 위한 기준보다 넓어야 하며, ‘인적·개별적’ 지휘·감독이 아닌 ‘구조적·기능적 지배력’을 포착할 수 있어야 한다. 오늘날 원청은 직접적인 지시 없이도 작업 표준이나 전산 시스템만으로 하청을 완벽히 통제할 수 있기 때문이다.

특히, 불법파견은 ‘고용 책임’에 대한 것인데 반해 개정 노조법은 ‘교섭 책임’에 관한 것이라는 점에서 구분된다. 따라서 적법한 도급이어서 원청에게 직접 ‘고용 책임’이 인정되지 않더라도, 하청 근로자의 근로조

---

한다.”(김홍영·강주리, “택배회사를 대리점 택배기사에 대해 단체교섭의무를 지는 사용자로 인정한 중앙노동위원회 판정의 의미”, 『노동법연구』 제51호, 서울대노동법연구회, 2021, 415쪽)는 주장 역시 개정 노조법 시행 초기의 유연한 주문 형성 필요성의 관점에서 의미있는 지적이라 할 수 있다.

- 14) 김홍영, 권오성, 김린, 노호창, 방강수, 『노동분쟁에서 당사자 적격의 판단 기준에 관한 연구』, 중앙노동위원회 연구용역보고서, 2020, 160쪽에서는 “실질적 지배력 여부의 판단에 대하여는 현대중공업 판결에서 제시된 내용 및 ‘근로자파견과 도급 판단기준’ 등을 참고하는 것이 적절한 것으로 보인다.”는 기술이 등장한다. 이 보고서는 실질적 지배력의 판단기준을 구체적으로 모색한 초기 연구라 볼 수 있는데, 이후 연구가 거듭되면서 고용책임과 교섭책임을 구별해야 한다는 지적이 제기되었다(이정훈, “원청사업주의 실질적 지배력 판단지표”, 『노동법연구』 제54호, 서울대학교 노동법연구회, 2023, 427쪽에서는 “‘업무지휘·감독’ 지표는 불법파견 여부를 판단하는 기준으로서 의미가 있겠지만 원청사업주의 실질적 지배력을 판단하는 지표로는 큰 의미가 없다고 할 것이다. 만약 근로자파견의 핵심지표이자 원청사업주의고용의무가 결정되는 이 지표를 실질적 지배력 판단지표로 엄격히 적용한다면, 노조법상 사용자 개념은 다시 ‘근로계약관계’로 제한되어 다면적 노무제공관계가 보편화되는 노동현실에서 하청근로자들의 근로조건등을 향상시키고자 하는 노동3권의 근본적 목적은 달성되기 어려워지게 된다”라고 한다.).

건을 실질적으로 통제한다면 적어도 ‘교섭 책임’은 부담해야 한다. 이는 논리적으로 교섭 책임의 인정 문턱이 고용 책임의 인정 문턱보다 낮아야 함을 의미한다. 만약 기준(2)를 원청 사용자성의 필수적인 판단 요소로 엄격하게 해석하게 되면, 노동조합은 단체교섭을 요구하기 위해 불필요하게 ‘불법파견 인정기준에 준하는’ 수준의 업무의 필수성, 사업 편입성, 개별 근로자에 대한 지휘·감독성 등을 입증해야 한다는 문제가 발생한다. 이는 법 개정의 취지를 현저히 축소시킬 뿐만 아니라, 사용자로 하여금 교섭 책임을 인정하면 불법파견에 따른 직접 고용 책임까지 연쇄적으로 부담할 수 있다는 잘못된 인식을 가지게 해 원하청 교섭 자체를 기피하게 만드는 요인이 될 것이다.

### 3) 기준(3)의 문제점: 순환논리의 함정

“원청과의 교섭을 통해 결정할 필요성과 타당성여부”를 묻는 기준(3)은 순환논리의 오류에 빠질 위험이 있어 객관적이고 실무적인 판단 기준으로 기능하는데 한계가 있다. 논리적으로 교섭의 필요성이나 타당성은, 원청에게 실질적 지배력이 있다는 사실이 먼저 인정된 이후에 도출되는 ‘결론’에 해당한다. 즉, ‘원청이 실질적 지배력을 행사하고 있으므로’ 그와 ‘교섭할 필요성이 있다’고 판단하는 것이 올바른 순서이다. 그러나 이 기준은 거꾸로 그 결론이어야 할 교섭 필요성 자체를 다시 실질적 지배력을 판단하는 기준으로 제시하고 있다. 이는 ‘A와 교섭할 필요가 있기 때문에 A가 사용자다’라는 순환논리에 불과하다.

이 기준은 법원이나 노동위원회가 개별 사건에서 구체적 타당성을 도모하기 위한 결론을 도출함에 있어서는 도움이 될 수 있다. 특히, 실질적 지배력 개념이 입법화되기 이전의 경우와 같이 행정부나 사법부가 재량 판단의 여지가 많던 상황에서는 이러한 기준이 사건의 타당한 해결이라는 관점에서 유용했을 수도 있다. 하지만 입법화가 된 이후에는 더이상 그것이 판단 지침이 될 수는 없다. 객관적 성격이 떨어지기 때문이다. 즉, 기준(3)은 판단할 권한을 가진 주체에게 원청의 지배력은 일부 인정되나, 제반 사정을 고려할 때 교섭까지 할 필요성이나 타당성은 없다는 식의 자의적이고 정책적인 판단이 개입될 여지를 열어준다. 이 경우 법

의 행위지침으로서의 기능을 상실해 법적 예측 가능성을 저해하여 불필요한 분쟁 즉, 일단 법원이 판단을 내릴 때까지 기다려보자는 식의 버티기를 촉진하고, 노사관계의 사법화를 가중할 뿐이다. 이에 입법이 완성된 현시점에서는 이러한 사법부의 사후적 개입 여지는 축소할 필요가 있다. 이러한 기준이 없더라도 신의칙이나 권리남용 법리와 같이 법원이 구체적 타당성을 도모하기 위해 사용할 수 있는 일반적인 기준은 얼마든지 존재하며 이는 실질적 지배력 개념이 입법화된 지급도 여전히 유효하게 적용될 수 있다. 구체적 입법이 된 상황에서는 그에 대한 객관적 해석 기준이 최우선적으로 필요한바, 기준(3)을 개정법 하에서도 계속 유지하는 것은 타당하지 않다.

#### 4. 개정법을 위한 새로운 기준 제안

앞에서 살펴본 바와 같이, 법원이 제시한 판단기준은 해석론적 한계를 내포하고 있어 이를 개정 노조법 해석에 그대로 사용할 수는 없다. 따라서 개정 노조법에 따른 실질적 지배력 판단을 위한 합리적 기준을 정립하기 위한 시도를 해야 한다. 그러한 시도의 방법론으로 선례를 활용하 필요가 있다. 법원이 표면적으로 내세운 추상적 기준의 나열을 넘어, 실제 해당 사건에서 원청의 사용자성을 긍정(또는 부정)하게 만든 결정적인 사실관계와 실질적 판단 근거가 무엇이었는지를 분석하는 작업은 새로운 기준 마련을 위한 시험대가 되기에 충분하다.

이에 앞서 검토한 기존 판결들의 판단 방식과 그 한계를 넘어서기 위해, 다음과 같은 논증 과정을 거쳐 실질적 지배력의 판단 기준을 도출하였다. 첫째, 법원이 판결문 표면에 내세운 추상적인 판단 기준보다는, 실제 해당 사건에서 원청의 사용자성을 긍정하는데 기여한 결정적인 사실관계와 실질적 판단 근거를 귀납적으로 추출해 분석하였다. 둘째, 이를 토대로 고용 책임의 징표와는 명확히 구별되는 교섭 책임 고유의 독자적인 판단 표지를 재구성하였다. 이러한 과정을 통해 정립한 기준은 다음과 같다.

## 1) 새 기준의 개요

실질적 지배력은 추상적인 개념이 아니라, 구체적인 노사관계 현실 속에서 원청이 행사하는 통제력의 실체를 포착하기 위한 개념이다. 이를 위한 기준을 제시하면 다음과 같다.

첫째, “근로조건 결정의 구조적 통제력”이다. 이는 원청이 개별적인 근로조건을 넘어 하청의 노무관리 전반을 규율하는 기본 구조와 물적 토대를 장악하고 있는지를 묻는 기준이다. 둘째, “업무의 조직적 편입 또는 체계적 통제”이다. 직접적인 지휘·명령이 없더라도 시스템과 프로세스를 통해 하청 근로자를 원청의 사업체계 내로 편입시켜 통제하는지를 판단하는 기준이다. 셋째, “교섭 당사자로서의 실질적 지위”이다. 노동조합의 요구사항에 대해 실질적인 결정 권한과 이행 능력을 가진 최종적 주체가 누구인지를 기능적 관점에서 식별하는 기준이다.

이 세 가지 기준은 상호 배타적인 것이 아니라 유기적으로 연결되어 있으며, 종합적으로 고려되었을 때 비로소 ‘보이지 않는 사용자’의 실체를 명확히 드러낼 수 있다.

## 2) 제1기준: 근로조건 결정의 구조적 통제력

제1기준은 원청이 하청 근로자의 핵심 근로조건을 결정하는 기본 구조 내지 물적 토대를 장악하고 있는지에 관한 것이다. 이는 원청이 하청 업체가 자율적으로 임금 등 근로조건을 결정할 수 있는 구조적 여지를 제약하고 있는지를 살피는 징표이다.

법원은 주로 임금의 재원이 되는 대가의 통제를 통해 이를 확인한다. 한화오션 판결은 원청이 하청 근로자들에게 지급될 성과급이나 학자금의 총액을 결정하고, 하청업체는 이를 단순히 배분하는 역할에 그쳤다는 사실을 중시했다.<sup>15)</sup> 이는 원청이 하청의 임금 지급 능력 자체를 구조적·

15) “원고 회사의 사내하청업체들은 원고 회사가 정한 성과급 총액의 범위 내에서 각 업체별로 배정된 금액을 교부받고, 교부받은 금액을 소속 근로자들에게 성과급 명목으로 지급하여 왔는데, 근속연수에 따른 차등 외에는 근로자에 대한 개별 평가는 고려하지 않고 전체 사내하청근로자들에게 동일한 비율로 배분하였다(다(을나 제114호중 8쪽). 원고 회사가 성과급 총액

경제적으로 통제하고 있음을 의미한다. CJ대한통운 사건에서도 유사한 경제적 종속성이 확인된다. 원청인 택배사가 택배기사 수입의 원천인 수수료 기준을 사실상 일방적으로 결정할 수 있는 지위에 있다는 점이 사용자성 인정의 강력한 근거가 되었다.<sup>16)</sup> 나아가 임금 외의 사항에 대한 통제 역시 중요한 판단 요소이다. 현대제철 판결에서 보듯,<sup>17)</sup> 필수적인 대형 설비의 관리처분권한이 원청에게만 독점되어 있는 경우, 하청업체는 그 설비와 연동된 작업 방식, 속도, 안전 조치 등에 관하여 독자적인 결정권을 행사할 수 없다. 즉, 원청이 하청 근로자의 근로조건에 영향을 미치는 물적 토대를 장악하고 있는 것이다.

이러한 사례들은 원청이 경제적·구조적 힘을 통해 근로조건의 상한선과 하청 경영의 구조적 조건을 사전에 결정하고 있음을 보여준다.

### 3) 제2기준: 업무의 조직적 편입 또는 체계적 통제

제2기준은 하청 근로자의 업무 수행 과정이 원청의 사업 운영에 필수 불가결하게 통합되어 있거나, 원청이 설계한 절차에 따라 통제되는지를 살피는 것이다. 이는 전통적인 ‘조직적 편입’과 현대적인 ‘체계적 통제’라는 두 가지 징표를 포괄하는 개념으로, 산업의 특성에 따라 이들 중

---

을 결정하고 이를 각 사내하청업체에 교부하면 사내하청업체가 다시 그 소속 근로자에게 근로연수에 따른 성과급을 지급하는 구조는 원고 회사의 경영이 악화되었던 2017년 및 2018년을 제외하면 거의 대부분의 기간 동안 반복적으로 유지되어 왔다.”(한화오션 판결)

- 16) “집배점이 원고(원청)와 개별 집배점주들 사이의 서면 합의 등이 이루어지지 않는 한 이 사건 부속계약서 제3조 제2항, 제9조 제1항에 따라 원고가 사전에 정해둔 배송금지 기준표 및 이 사건 기준표에 따른 급지수수료를 준수할 의무를 부담하는 이상 그와 달리 일부 집배점에서 급지수수료와 다른 형태로 수수료를 책정한 사례가 있다는 사정만으로 배송수수료에 대한 원고의 지배·결정권한이 부정된다고 볼 수 없다.”(CJ대한통운 1심 판결)
- 17) “원고 회사는 크레인, 각종 자재 및 제품을 운송하는 특수 궤도차량, 생산 라인을 구성하는 각종 전산장비, 고로 압연에 사용되는 롤 등 이 사건 사업장에서 사용되는 생산수단 일체를 소유하고 있다. 생산에 필수적인 대형 설비에 대한 관리처분 권한이 전혀 없는 사내하청업체가 이 사건 사업장에서 발생하는 노동안전 문제에 관하여 제시할 수 있는 해결책은 한정적이다.”(현대제철 판결)

어느 하나라도 충족되어 하청의 독자적인 업무 수행이 사실상 불가능하거나 무의미하다면 실질적 지배력이 긍정되어야 한다.

특히, 오늘날의 기업은 ‘공급망 관리(Supply Chain Management)’에 기반하여 사업체계를 구축하는 전략을 택하는 경우가 많은데, 이를 통해 비용 절감을 위해 고용을 외주화하면서도 품질·납기 준수를 위한 통제는 내재화한다. 즉, 고용은 가능한 밖에 두되 불가결한 통제는 하는 전략이다. 원청은 이를 위해 법적으로 분리된 하청업체를 자신의 생산 및 업무 조직뿐 아니라 운영체계 내에 기능적으로 완벽히 결합시키는데, 이러한 통제 매커니즘을 이 글에서는 ‘사업체계’라 정의하자.<sup>18)</sup> 이 ‘사업체계’는 원청의 물리적 조직과 운영 체계를 모두 포괄하는 상위 개념이다. 즉, 원청이 구축한 ‘사업체계’는 단순한 경영 효율화 수단을 넘어, 하청 근로자의 노동 과정을 원청의 경영 리듬에 종속시키는 실질적 지배력의 행사 기제로 작동한다. 따라서 하청이 이 ‘사업체계’에 편입되었다는 것은 곧 원청의 지배력 하에 놓여 있음을 의미하며 반대로 ‘사업체계’에서의 배제가 곧 하청업체의 사실상 폐업으로 귀결된다면 이 역시 지배력의 존재를 방증하는 것이다.

원청의 지배력은 이 사업체계를 통해 두 가지 양상으로 발현된다. 즉, 하청 근로자를 자신의 사업 조직 내로 물리적·기능적으로 통합시키는 ‘조직적 편입’의 형태로 나타나거나, 혹은 IT, AI 등 기술과 표준화된 프로세스를 통해 업무 수행 과정 내지 전체 사업체계의 운영을 장악하는 ‘체계적 통제’의 형태가 그것이다. 업종이나 산업의 특성에 따라 이 두 가지 징표는 중첩되어 나타나기도 하고(예컨대 사내하청), 어느 하나가 두드러지게 나타나기도 한다(예컨대, 시설관리, 플랫폼노동). 중요한 것은 두 가지 현상 중 어느 하나라도 원청이 하청의 업무 수행에 대해 실

18) 참고로, 불법파견의 판단기준에서의 ‘사업체계 편입’은 원청의 사업장내 혹은 조직내 위계질서에 포함되는 경우를 지칭하는 인적, 장소적 성격이 강하다. 실질적 지배력의 판단기준으로 제시하는 사업체계의 편입은 인적, 장소적 성격뿐 아니라 공급망 관점에서 기능적, 운영적 통합까지 포함하는 확장된 의미라 할 수 있다. 불법파견과의 구분이 필요하다는 점을 II.3.나에서 논증하였는데, 법원의 기준(2)도 이렇게 확장된 의미로 해석된다면 불법파견과의 구분 문제를 완화할 수 있을 것이다.



질적인 영향력을 행사하고 있음을 보여준다면, 이는 원청의 사용자성을 긍정하는 유력한 징표로 삼아야 한다는 점이다. 즉, 이는 병렬적 요건(즉, and)이 아니라, 원청의 지배력이 발현되는 다양한 양상을 포괄하는 선택적 징표(즉, or)로 이해되어야 한다

이러한 관점은 법원의 판결에서도 확인할 수 있다. 예컨대, 현대제철 판결은 원청이 구축한 전산시스템(Manufacturing Execution System)을 통해 작업 정보가 실시간으로 전달되고, 하청 근로자가 이에 전적으로 의존하여 업무를 수행한다는 사실을 지배력 인정의 핵심 근거로 삼았다.<sup>19)</sup> CJ대한통운 사건 역시 택배기사들이 원청이 제공하는 모바일 애플리케이션을 통해 배송 업무 전반을 관리받고 표준화된 업무 절차를 따른다는 점이 중요하게 고려되었다.<sup>20)21)</sup>

#### 4) 제3기준: 교섭 당사자로서의 실질적 지위

세 번째 기준은 ‘해당 교섭 의제를 실질적으로 해결할 권한과 능력을

- 
- 19) “조업 업무 중 제품 출고 업무를 수행하는 사내하청업체 근로자는 원고 회사 소유의 PDA를 통해 자신이 수행해야 할 작업 내용을 확인하고, 전 과정에서 원고 회사의 MES에 의존하여 작업을 진행한다. 출고 제품의 상차에 사용되는 크레인 운전도 주로 사내하청업체 근로자가 수행하는데, 이 경우에도 원고 회사의 MES를 통해 조업 업무를 수행하는 근로자와 동일한 작업지시 화면을 실시간으로 확인하며 협업하고, 제품의 적재 차량, 위치, 상차 준비사항 등도 모두 MES를 통해 전달받는다. 출고 제품의 하자 여부, 제품 번호, 사양 등은 해당 업무를 수행하는 사내하청업체 근로자가 MES와 연동된 PDA를 통해 직접 확인하고 이상이 있을 경우 원고 회사에 직접 보고한다(올나 제11 내지 16호증).”(현대제철 판결)
- 20) “집배점 택배기사들이 담당하는 집화 및 배송 업무는 위 업무 중 가장 본질적이고 필수적이며 상시적인 업무로서, 원고가 구축한 모바일 어플리케이션, 전산시스템 등을 통해 전자적으로 통합 관리되는 등 원고가 운영하는 전국적인 규모의 운송시스템과 사업 체계에 편입되어 있다. 즉, 집배점과 집배점 택배기사들은 원고가 택배사업을 영위하기 위해 유기적으로 조직한 사업 중 일부 업무를 담당하고 있다”(CJ대한통운 1심 판결)
- 21) 한편, 이러한 ‘시스템을 통한 간접 통제’는 미 연방노동관계위원회(NLRB)의 Browning-Ferris 결정에서도 확인이 된다(주2 참조). 이 결정은 ‘지배력’의 행사가 반드시 직접적인 지휘·명령의 형태를 띠 필요가 없으며, 조직적 편입 내지 체계적 통합을 통해서도 충분히 발현될 수 있음을 시사한다.

누가 가지고 있는가?’라는 실용적·기능적 물음에 기초한다. 이는 단순히 ‘교섭할 필요가 있다’는 당위론이나 순환논리에서 벗어나, 노동쟁의를 실제로 종결짓고 합의를 이행할 수 있는 ‘문제 해결의 열쇠’를 쥔 자를 식별하는 기준이다. 좀 더 세분하자면, ‘하청의 기능적 한계와 해결 불가능성’과 ‘원청의 결정적·최종적 역할 수행 가능성’이다.

먼저, 하청의 기능적 한계와 해결 불가능성의 경우 하청 노동조합의 요구안에 대해 하청업체가 독자적으로 수용할 권한이나 재원이 구조적으로 결여되어 있다는 점이다. 하청업체가 교섭 테이블에 나오더라도 “우리는 권한이 없다”, “원청이 결정할 사항이다”라는 답변만 반복할 수밖에 없는 상황이라면, 이는 하청이 해당 의제에 관하여 사용자로서의 ‘처분 권한’을 상실했음을 방증한다. 이와 관련하여 CJ대한통운 판결에서 법원은 노동조합의 ‘서브터미널 작업환경 개선’ 관련 의제에 대하여, 해당 시설물은 원청인 CJ대한통운이 전적으로 소유·관리하고 있고 하청인 집배점은 이에 대한 아무런 관리 권한이 없다는 점을 지적하였다.<sup>22)</sup> 즉, 집배점에게 이에 대한 교섭 의무를 부과하는 것은 권한 없는 자와의 교섭과 같아 무의미하다는 취지로 판단한 것이다.

다음으로 원청의 결정적·최종적 역할 수행가능성이라는 징표는 문제의 해결이 오직 원청의 결단 예컨대, 정책 변경, 예산 증액, 설비 투자, 승인 등을 통해서만 가능하다는 점을 포착한 것이다. 노동조합의 요구가

22) “집배점은 직접 택배업무 수행을 위한 터미널이나 컨베이어벨트, 물류창고와 같은 독립적인 물적·인적 시설을 갖춘 것이 아니라, 택배기사를 관리할 수 있는 소규모 사무실과 컴퓨터 정도의 시설만을 갖춘 채 택배기사들의 집화 및 배송업무 관리를 주된 업무로 하고 있고, 뒤에서 보는 바와 같이 원고가 일방적으로 정하는 계약조건이나 거래상 지위의 열위로 인해 집배점이 독자적으로 결정할 수 있는 근로조건은 한정적이다. (중략) 서브터미널에서의 배송상품 인수시간 및 집화상품 인도시간은 택배상품의 물량, 원고와 별도 도급계약을 체결한 간선차량의 수 및 출발시각, 원고와 도급계약을 체결한 협력업체 소속 인력들의 작업 속도, 원고가 배타적으로 지배하고 있는 서브터미널의 설비 (월소터, 분류레일의 수, 택배차량의 집안 공간 등), 이 사건 사회적 합의에 따른 원고의 분류인력 투입 규모 등에 절대적으로 영향을 받을 수밖에 없고, 이는 원고가 실질적·구체적으로 지배·결정할 수 있는 사항에 해당한다.”(CJ대한통운 1심 판결)

개별 근로계약의 범위를 넘어 사업장의 안전, 물량 배분 시스템, 전체적인 임금 구조 등 구조적인 사안에 대한 것일수록 원청의 역할은 결정적이 된다. CJ대한통운 1심 판결에서 서버터미널 작업개선 의제와 관련하여 “집배점 택배기사 1인당 1분류하차장 보장, 우천시 택배상품 보호 시설 설치에 서버터미널의 설비에 관한 것으로, 서버터미널 시설의 소유자인 원고가 실질적·구체적으로 지배·결정할 수 있는 사항에 해당함이 분명하다.”라고 판시한 부분이 이에 해당한다. 원청이 소유한 시설의 사용 문제를 하청 차원에서 독자적으로 해결할 수 없는 사안이기 때문이다.

요컨대 이 기준은 ‘실질적 권한이 있는 곳에 책임이 있다’는 원칙을 단체교섭의 영역에서 구체화한 것으로 형식적인 계약 당사자를 넘어 실효성 있는 단체교섭을 보장하는데 기여한다.

### 5) 종합적 판단과 지배력 확장에 대한 통제 기능

앞서 제시한 세 가지 기준은 ‘실질적 지배력’을 판단하기 위해 개별적으로 분절된 독립적인 요건은 아니다. 이들은 원청이 행사하는 지배력이라는 하나의 실체를 서로 다른 측면—경제적, 구조적, 조직적, 기능적 측면—에서 포착한 상호 연관된 징표 또는 판단 요소로 이해되어야 한다.

따라서 실무적 판단에 있어서는 이 세 가지 기준이 기계적으로 모두 충족되어야만 사용자성이 인정된다는 식의 경직된 도식은 바람직하지 않다. 각 기준은 업종이나 산업의 특성, 원하청 관계의 구체적 모습에 따라 그 발현 정도가 다를 수 있기 때문이다. 예컨대, 플랫폼노동과 같이 ‘업무의 체계적 통제력’이 극도로 강하게 나타나는 경우에는, 다른 기준의 징표가 다소 약하더라도 실질적 지배력은 긍정될 수 있다.

동시에, 이 세 가지의 기준은 실질적 지배력의 인정 범위가 무한정 확장되는 것을 제어하는 합리적인 ‘통제 장치’로서도 기능한다. 개정법에 대한 비판 중 하나로 “단순한 거래처나 고객까지도 사용자가 될 수 있다”는 우려가 있다. 그러나 세 가지 기준을 적용하면 단순한 혹은 경쟁법적 관점의 ‘거래상 영향력’과 노동법적 ‘실질적 지배력’은 명확히 차별된다. 일례로 원청 운수회사에 유류를 공급하는 주유소나, 대기업에 사무용품을 납품하는 문구회사의 경우를 상정해 보자. 원청은 이들과의

거래에서 물량을 조절하거나 단가를 협상하는 등 우월한 거래상 지위를 행사할 수 있다. 그러나 원청이 주유소 직원의 임금 산정 구조나 근로조건의 기본 틀을 결정하지는 않으며(제1기준 부재), 문구회사 직원의 업무 수행 과정을 자사의 ‘사업체계’ 내로 편입시켜 시스템적으로 통제하지도 않는다(제2기준 부재). 나아가 이들 직원의 임금 인상 요구 등을 원청이 해결해 줄 수 있는 기능적 권한이나 지위도 보유하고 있지 않다(제3기준 부재).

결국 세 가지 기준은 원청의 영향력이 단순히 시장에서의 거래 조건을 넘어, 하청 근로자의 노동 과정과 근로조건을 실질적으로 장악했는지를 가려내는 시금석이 될 수 있다. 이러한 종합적·실질적 판단 방식을 통해 영동한 제3자에게까지 책임을 묻지 않도록 하여 개정법의 입법 목적과 법적 안정성을 동시에 담보할 수 있을 것이다.

## 5. 유형별 적용 예시

앞서 정립한 기준이 실제 현장에서 어떻게 작동하는지 검증할 필요가 있는바, 이를 위해 대표적인 간접고용 유형 네 가지에 대해 각 기준을 적용해 본다. 이를 통해 추상적인 법리가 구체적인 현실에서 어떻게 구현될 수 있는지 그 실효성을 가늠해 볼 수 있다. 논의의 편의상 이하에서는 각 기준별로 ‘근로조건 결정의 구조적 통제력’은 “구조적 통제력”으로, ‘업무의 조직적 편입 또는 체계적 통제’는 “조직적 통제력”으로, ‘교섭 당사자로서의 실질적 지위’는 “실질적 지위”로 줄여 쓴다.

### 1) 유형 (1): 원청 핵심 사업 연계 하청 (제조업 사내하청)

조선, 자동차, 철강 산업 등 제조업 분야에서 흔히 볼 수 있는 이 유형은 하청 근로자가 원청의 사업장 내에서<sup>23)</sup> 원청의 주된 생산 공정의 일

<sup>23)</sup> 원청의 ‘사업장 내’에서 하청이 업무를 수행하는 경우를 전제로 한 검토이나, ‘사업장 밖’ 하청의 경우에도 동일한 틀로 검토가 가능하다. 이 경우에는 제2기준과 관련하여 조직적 편입보다는 체계적 통제의 면이 더 부각될 것이다.

부를 담당하며, 생산 라인이 물리적·기능적으로 밀접하게 연동되어 있다는 특징이 있다.

새 기준의 관점에서 실질적 지배력 유무를 살펴보자. ① 구조적 통제력의 관점에서, 원청이 결정하는 도급 단가나 기성금은 하청업체 총매출의 절대적 비중을 차지하여, 사실상 하청 근로자의 임금 총액과 인상 여력을 직접적으로 결정한다. 또한, 필수적인 생산 설비의 소유권과 관리권을 원청이 독점하고 있어 작업 환경과 안전 조치에 대한 물적 토대를 장악한다. 즉, 근로조건 결정을 구조적으로 통제하는 것이다. ② 조직적 통제력의 경우, 사내하청에 있어 하청업체의 업무는 원청이 관리하는 사업체계의 일부를 구성하는 경우가 일반적이다. 원청의 생산관리시스템(MES, ERP 등)이 하청 근로자의 작업량, 순서, 속도를 실시간으로 통제하는 경우가 많고, 이 경우 하청 현장 관리자의 지휘 명령은 원청 시스템에 따른 운영 지시를 단순히 전달하는 기계적 역할에 그칠 뿐, 독자적인 업무 통제권은 부인되기 쉽다. 원청이 체계적 통제를 한다고 볼 수 있다. ③ 실질적 지위에 있어서, 하청 노동조합이 임금 인상이나 설비 개선을 요구하더라도, 하청업체는 원청의 단가 인상이나 설비 투자 승인 없이는 이를 해결할 재원도, 권한도 없다.

이상의 점을 고려할 때 이 유형은 형식적인 도급 내지 위탁 계약의 외관에도 불구하고 세 가지 기준이 모두 강력한 형태로 충족되는 전형적인 사례라 평가할 수 있다. 생산 공정의 연동성과 조직적 전속성으로 인해 원청의 실질적 지배력이 전방위적으로 미치고 있으므로, 원청의 사용자성이 인정될 가능성이 매우 높다.

## 2) 유형 (2): 원청 상시 필요업무 위탁 (시설관리형 하청)

이 유형은 청소, 경비, 시설관리 등 원청의 부수적 업무를 위탁하는 유형으로, 주로 ‘최저가 경쟁 입찰’을 통해 용역 계약이 체결된다는 특징이 있다. 새로운 기준의 관점에서 실질적 지배력 유무를 검토하면, ① 구조적 통제력과 관련하여 이 유형의 하청관계의 핵심은 ‘최저가 입찰’ 방식 그 자체라 볼 수 있다. 원청이 예정 가격을 산정하면서 최저임금 수준의 인건비와 최소한의 인력을 기준으로 낙찰자가 선정되도록 설계하

면, 낙찰받은 하청업체는 그 범위를 넘어선 근로조건 개선을 할 재량적 여지가 원천적으로 봉쇄된다. ② 조직적 통제력의 경우, 원청은 ‘과업지시서’나 ‘시방서’를 통해 업무 수행 방식과 절차를 구체적으로 정하고, 원청 시설의 보안 규정 등을 통해 하청 근로자의 출퇴근 시간과 장소, 근로시간과 휴게시간은 물론이고 연차휴가 사용까지 통제하기도 한다. 이는 사실상 원청의 조직적 규율 체계 내로 하청 근로자를 편입시키는 결과를 낳는다. ③ 실질적 지위 인정여부와 관련하여, 하청업체는 정해진 용역비 내에서 인력을 운영해야 하므로, 인력 충원이나 휴가 및 휴게 시간 보장과 같은 요구에 대해 독자적인 해결 능력이 없다. 오직 원청의 계약 변경만이 유일한 해법일 것이다.

이 유형은 제조업 사내하청에 비해 업무 수행 자체의 독립성은 상대적으로 높다고 볼 수 있다. 그러나 ‘최저가 입찰’을 거친다는 계약 구조 자체가 근로조건, 그중에서도 가장 핵심이 되는 임금을 강력하게 통제하고 있고 비용투입과 연관된 일체의 근로조건을 제약한다는 점에서 하청업체의 ‘기능적 무능력’이 두드러지므로, 이 경우 역시 원청의 실질적 지배력이 인정될 가능성이 매우 높다.

### 3) 유형 (3): 모회사-자회사 관계 (그룹사 지배)

지주회사나 모회사는 자회사에 대한 지분 소유를 통해 자회사의 경영권을 행사한다. 모자회사 관계는 단일한 목적하에 경영의 편의를 도모하고자 별개의 법인으로 분리되어 있을 뿐이라는 점에서 상호 독립한 사업자인 원하청 관계보다 더욱 밀접한 관계에 있고, 노동관계에 미치는 영향력 또한 상당하다는 점에서 일반적인 원하청 관계와는 질적인 차이가 있다.<sup>24)</sup> 세 가지 기준의 관점에서 실질적 지배력 유무를 살펴보자. ① 구조적 통제력의 관점에서, 모회사는, 특히 그것이 그룹의 지주회사인 경우 주주권 행사를 넘어 그룹 차원의 경영 목표(예컨대, KPI)나 예산 편성 지침을 하달하여 자회사의 총인건비 규모를 사전적으로 통제한다. 이는 자회사의 독자적인 임금 교섭 능력을 구조적으로 제약하는 요소라

24) 김홍영 외 4, 앞의 보고서, 69쪽.

볼 수 있다. ② 조직적 통제력에 있어서도 그룹 공통의 통합 인사 시스템, 그룹웨어 같은 공동 전산망, 모회사 출신 임직원의 자회사 경영진 파견 또는 겸직 등을 통해 자회사의 핵심적인 인사·노무 관리가 모회사의 통제하에 놓이는 경우가 많다. ③ 실질적 지위에 있어서 자회사 노조가 그룹 차원의 공통된 근로조건 개선(예를 들면, 모회사 소속 직원과의 불합리한 차별 시정)을 요구할 경우, 자회사 경영진은 이를 독자적으로 수용할 권한이나 재원이 없으며 그룹 본부(지주회사 등 모회사)의 정책적 결단이 필수적이다.

모자회사 관계는 ‘별개의 법인격’을 가지고 있지만 경영을 위한 목적의 지분 소유관계가 있다는 고유한 특색이 있어 신중한 접근이 필요하다고 볼 수 있다. 그러나 상법상의 형식적 법인격 독립성이 노동법상의 실질적 사용자 책임을 면제하는 방패가 될 수는 없다.<sup>25)</sup> 세 기준을 적용한 결과 모회사가 자회사의 핵심 근로조건을 실질적으로 지배·결정하고 있음이 확인된다면, 법인격의 외피와 무관하게 모회사의 사용자성을 인정할 수 있어야 한다.<sup>26)</sup> 사실 일반 하청업체의 경우에는 별개의 법인격을 지니고 있으면서 지분의 연관조차 없는데도 앞에서 본 유형(1), (2)의 경우 실질적 지배력을 인정하는데 특별한 장애가 존재하지 않는다는 점을 상기해 볼 필요가 있다.

25) 같은 취지로, 김홍영 외 4, 앞의 보고서, 52쪽. 한편, 상법학계에서도 모회사 주주의 관점에서 모회사 이사에 대한 책임 추궁의 필요성을 주장하며 다음과 같은 지적이 있다. “모회사, 지배주주, 이사는 자회사에 대한 “법인의 틀을 넘어” 그 영향력을 행사하고 있는데, 그에 대한 책임은 “법인격이 독립되어 있으므로” 불가능하다는 것은 구체적 정의에 맞지 않다.”(최민용, “모자회사와 기업지배구조”, 『기업법연구』 제32권 제3호, 한국기업법학회, 2018, 41쪽).

26) 참고로, 일본에서는 후나이 전기 사건에서 도쿠시마 지방재판소는 모회사가 자회사 근로자를 직접적으로 지배하고 있지는 않더라도 모회사와 자회사와의 밀접한 관계에 주목하여 모회사에게 단체교섭 응낙 의무를 인정하기도 하였다(船井電機事件: 徳島地決 1987. 7. 14.). 이 판결에 대한 소개는 김홍영 외 4, 앞의 보고서, 50-51쪽 참조.

#### 4) 유형 (4): 공공부문 민간위탁 관계

정부나 지자체가 공공 서비스를 민간에 위탁하는 경우로, 원청인 공공기관 역시 상급 기관의 법령과 예산 통제를 받는다는 특수성이 있다. 즉, 공공부문에서 관이 발주하는 사업을 수행하는 민간사업장 소속 근로자의 근로조건은 공공기관이 사실상 결정하고 해당 사업을 실행하는 민간사업주는 실질적인 결정권이 사실상 없다는 점에서 여느 원하청 관계보다도 원청인 공공기관이 민간사업주 노동조합에 미치는 영향력이 강하다.<sup>27)</sup> 이러한 관계에 세 가지 기준을 적용해 보자. ① 구조적 통제력의 경우, 시설관리형 하청과 유사하게 입찰 등 계약 체결을 위한 설계 단계에서 임금의 상한선이 사실상 결정된다. 특히 용역원가 산정 시 적용되는 정부의 각종 지침이 강력한 구조적 통제 기제로 작용한다. ② 조직적 통제력과 관련하여서는, 공공 서비스의 품질 유지 및 통일성을 명분으로 과업지시서를 통해 업무 수행 과정이 상세히 통제되며, 민원 발생 등을 이유로 담당 공무원이 수시로 관리·감독권을 행사하는 경우가 빈번하다. ③ 실질적 지위에 있어서 공공기관은 예산 편성에 있어 의회나 기획재정부의 최종 통제를 받지만, 민간업체와 비교할 때 상급기관에 대한 예산 편성 요구권과 계약관계 설정 권한을 가진다는 점에서 실질적 권한이 있다는 점을 부인하기는 어렵다. 다만, 공공부문은 예산과 인력 운용에 있어 법령상 제약이 있고 최종 결정권이 의회 등에 유보되어 있어 원청이 민간기업인 경우와 동일하게 보기는 어렵다는 난점이 있다. 그러나 공공기관은 적어도 예산 편성 요구권 등 근로조건 개선을 위한 실질적 권한을 보유한 ‘최근접 사용자’라는 점, 국가는 모범사용자로서의 책무를 다해야 한다는 점 등을 고려할 때, 이러한 특수성이 사용자성을 부정하는 근거가 되어서는 안 될 것이다. 오히려 공공기관이 계약 설계 및 예산 요구 권한을 통해 실질적 영향력을 행사하고 있다면 사용자성을 적극적으로 인정함이 타당하다.

27) 김홍영 외 4, 앞의 보고서, 69쪽.



## 6. 소결: 세 가지 판단 기준의 의의와 실무적 과제

개정 노조법의 안착과 성공은 법문의 추상성을 얼마나 합리적이고 일관된 해석론으로 구체화하느냐에 달려 있다. 앞서 제안한 ‘근로조건 결정의 구조적 통제력’, ‘업무의 조직적 편입 또는 체계적 통제’, 그리고 ‘교섭 당사자로서의 실질적 지위’라는 3가지 기준은 개정 노조법상 사용자성 판단에 있어 다음과 같은 이론적·실무적 함의를 가진다.

첫째, 이 기준은 ‘교섭 책임’을 ‘고용 책임(즉, 불법파견)’과 명확히 구별하는 독자적인 판단 틀을 제공한다. 이는 교섭 의무의 발생 문턱을 고용 의무보다 낮게 설정함으로써 실질적 지배력이 있는 자에게 교섭 책임을 부과하려는 법 개정의 취지에 부합한다. 둘째, 전통적인 지휘·명령 관계를 넘어 도급비 결정, 조직적 편입, 체계적 통제, 최종 결정 권한 등 현대 노동시장에서 작동하는 비가시적이고 경제적·구조적인 통제력을 포착할 수 있게 해준다. 셋째, ‘교섭 필요성’과 같은 추상적이고 순환적인 논리에서 벗어나, ‘실제로 누가 이 문제를 해결할 수 있는가’라는 기능적 관점에서 실질적인 교섭 상대를 식별하게 함으로써 실무적 판단의 예측 가능성을 제고한다.

이러한 기준은 노사정 각 주체에게 구체적인 실천 과제를 부여하는 기능도 한다. 노동조합은 막연한 정황 주장이 아닌, 이 기준들에 부합하는 구체적인 증거를 확보하여 교섭 요구의 정당성을 입증하는 데 역량을 집중하면 된다. 원청은 계약관계가 없다고만 주장하며 외면하기보다는 제시된 기준에 비추어 자신의 실질적 지배력 행사 여부를 냉정하게 점검하고, 필요한 경우 교섭에 대비하는 전향적인 자세가 요구된다. 나아가 법원과 노동위원회는 과거 파견법상의 사용자성 판단 관성에서 탈피하여, 집단적 노사관계법 고유의 ‘교섭 책임’ 법리를 적극적으로 형성하고 발전시켜 나가야 할 것이다.

### III. 교섭창구단일화 절차 적용 여부

#### 1. 문제의 소재: 원청청 교섭과 ‘하나의 사업 또는 사업장’

개정 노조법 제2조에 따라 원청이 하청 근로자의 근로조건에 대해 실질적 지배력을 행사하는 범위 내에서 사용자로서의 지위를 인정받게 될 경우, 실무상 가장 즉각적이고 복잡한 쟁점으로 부상한 것이 바로 교섭창구단일화 절차(노조법 제29조의2) 적용 여부이다.

노조법 제29조 제1항은 노동조합 대표자의 교섭 권한을 원칙적으로 보장하고 있으나, 동법 제29조의2 제1항은 “하나의 사업 또는 사업장”(이하 “하나의 사업”이라고만 한다)에 복수의 노동조합이 존재하는 경우 교섭대표노동조합을 정하여 교섭을 요구하도록 강제함으로써 이를 절차적으로 제한하고 있다. 동법 제29조의3 제1항도 교섭대표노동조합을 결정하여야 하는 단위를 하나의 사업으로 한다. 문제는 개정법이 상정하는 원청과 하청 노조 간의 관계가 이러한 ‘하나의 사업’이라는 전제 조건에 부합하는가이다. 만약 원청의 사용자성이 인정되어 하청 노동조합이 원청에게 교섭을 요구할 때, 이들이 ① 원청의 정규직 노동조합이나 ② 하청의 다른 노동조합들과 단일한 창구를 구성해야 하는지, 아니면 이러한 절차 없이 독자적인 교섭권을 행사할 수 있는지에 대해 현행법은 명확한 해답을 제시하지 않고 있다.

이에 대하여 창구단일화 제도의 취지와 조문의 해석을 두고 필요여부, 필요시 단일화의 단위를 어떻게 볼 것인지와 관련하여 다음과 같이 견해가 제시될 수 있다.<sup>28)</sup>

첫째, 불요설(不要說)이다(자율교섭설이라고도 한다). 이 견해는 원청 교섭에는 창구단일화 절차가 적용되지 않는다는 입장이다.<sup>29)</sup> 이 입장

28) 권오성, “하청노조의 단체교섭에 관한 쟁점”, 『노동법률』 2021년 6월호, 중앙경제사, 54-55쪽 및 김민기, 앞의 논문, 287쪽 등에서도 이러한 유형의 견해가 가능하다는 점을 제시하였다.

29) 이러한 입장으로는 “교섭창구단일화제도가 도급노동자 등에게 그와 직접고용관계에 있는 사용자와의 기업별 교섭만을 제도적으로 또는 사실상 강제한다면, 도급노동자 등의 위와 같은 단체교섭이 불가능하게 되므로 그들의

은 현행 창구단일화 제도가 기업별 노조 체제를 전제로 설계되었음에 주목한다. 원청과 하청 노조의 관계는 기업의 울타리 즉 사용자가 지배력을 가진다고 응답 인정되는 범위라 할 수 있는 ‘사업’의 범위를 넘어서는 초기업적 성격을 띠므로 ‘하나의 사업’ 개념을 적용할 여지가 없으며, 단체교섭권이라는 기본권을 제한하는 예외 규정인 제29조의2를 확장 해석해서는 안 된다는 헌법적 요청을 근거로 한다.

둘째, 필요설(必要說)이다. 이 견해는 교섭의 효율성 도모와 질서 유지를 위해 원하청 교섭에도 창구단일화가 필요하다는 입장이다.<sup>30)</sup> 이는 교섭 비용의 절감과 노사관계의 혼란 방지라는 제도의 도입 취지를 중시한다. 필요설은 다시 단일화의 단위를 어디로 볼 것인지에 따라, (i) 원청과 모든 하청을 포괄하여 하나의 단위로 보는 ‘원청 단위설’과,<sup>31)</sup> (ii) 하

---

단체교섭권은 본질적으로 침해된다. 따라서 교섭창구단일화 절차를 직접 고용관계를 전제로 하는 기업별 교섭에만 적용되는 절차로 이해(적용)하고, 도급노동자 등의 위와 같은 단체교섭은 교섭창구단일화 절차를 거치지 않고도 가능하다고 하여야 한다.”(장영석, “간접고용과 교섭창구단일화 절차”, 『노동법학』 제73호, 한국노동법학회, 2020, 57-58쪽).

30) 김홍영 외 4, 앞의 보고서, 67-68쪽은 하청노동조합과 원청사업주의 사이의 관계는 마치 산별교섭과 유사한 구조라는 점에서 기업별 노조를 전제로 설계된 교섭창구단일화절차와는 정합성이 떨어지는 점을 인정하면서도, 현행 노조법의 해석론으로는 교섭창구단일화절차를 거치는 것이 불가피하다고 보았다.

31) 이승욱 교수는 개정 노조법 하에서는 “직접사용자든 간접사용자든 노동조합법상 사용자에 해당하기 때문에 그 ‘사업 또는 사업장’에 복수노조가 병존한다면, 교섭창구단일화절차를 거쳐야 하는 것으로 해석할 수 밖에 없다. 노사관계의 실태를 보더라도, 하청기업이 수백개에 이르는 경우가 적지 않은데, 이 경우 원청이 모든 하청기업 노조와 개별 교섭을 하여야 한다면 교섭의 효율성과 근로조건 통일이라는 측면에서 바람직하지 않은 결과가 발생할 가능성이 높다. 이런 점을 고려하면 노조는 간접사용자 사업에서 교섭창구단일화절차를 거쳐야 할 것이다”라고 본다(이승욱, “노동조합법 제2·3조 개정의 쟁점과 향후 과제 - 미국과의 비교를 중심으로 -”, 『노동법학』 제95호, 한국노동법학회, 2025, 51쪽)

최근 고용노동부는 2025. 11. 25. 노조법 시행령 개정안을 입법예고 하면서 발표한 보도자료에서 “원청 사용자와 하청노조 간 교섭은 원청 사용자의 사업(장)을 기준으로 하되”라고 표현하였다(고용노동부, “원·하청 노사의 실질적 교섭 촉진을 위한 「노동조합법」 시행령 입법예고(11.25.~1.5.)”, 2025.

청업체별로 단일화를 거쳐야 한다는 ‘하청 단위설’로 나뉘고, 하청단위설은 다시 (a) 개별 하청 단위설<sup>32)</sup> 또는 (b) 전체 하청 단위설 등으로 나뉠 수 있다.

이러한 해석론의 대립은 단순한 절차의 문제를 넘어, 하청 노동조합의 헌법상 단체교섭권이 실질적으로 보장될 수 있는가와 직결된다.

## 2. 법원의 입장

이 문제에 대한 본격적인 검토에 앞서, 비록 개정전 노조법이 적용된 사건에서의 판단이기는 하나 법원에서 어떤 입장을 취하고 있는지 살펴보자. CJ대한통운 1심 판결에서는 교섭창구단일화 규정을 근거로 근로자와 직접적 근로관계가 존재하지 않는 사용자는 노조법상 사용자에 해당할 수 없다는 사측의 주장에 대하여 “노동3권은 법률이 없더라도 헌

---

11. 24.자 보도자료. 시행령 개정안은 교섭단위 분리를 종전보다 원활하게 이루어질 수 있도록 하는 것을 주요 내용으로 하는데, 이에 따르면 정부는 원하청교섭시 일단 창구단일화절차를 개시하되 추후 노동위원회를 통해 교섭단위를 분리하는 방향으로 제도를 운영하겠다는 취지로 이해된다.

- 32) 이러한 입장으로는 중앙노동위원회 2022. 3. 24. 판정 중앙2021부노268 (현 대체철 판결의 원처분). 이 판정문에는 “사내하청 근로자들로 조직된 노동조합의 단체교섭 상대방이 사내하청 사용자뿐만 아니라 원청 사용자까지 확대되더라도 단체교섭 대상은 사내하청 근로자들의 노동조건임에는 변화가 없으며 근로자들의 이해관계의 공통성을 기반으로 교섭대표노동조합을 정해야 하는 교섭단위는 사내하청 근로자들이 종사하는 ‘하청 사업’으로 그대로 유지된다.”라고 실시하였다.

이외에 “근로계약 등을 체결하지 않은 ‘원사업주 이외의 사업주(원청을 의미한다)’가 원사업주(하청을 말한다) 소속 근로자의 기본적인 노동조건 등에 관하여 일정 부분 실질적이고 구체적으로 지배 결정할 수 있는 지위에 있어 그 법률적 또는 사실적인 권한과 책임의 한도 내에서 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자로 인정된다고 하더라도, 교섭창구단일화절차는 원사업주의 사업 또는 사업장을 대상으로 하여야 한다.”(이승욱, 앞의 논문, 141쪽. 이승욱 교수는 법 개정전과 후를 다르게 평가한다. 주31 참조.), “교섭단위를 ‘개별 하청’으로 보는 것이 노조법의 문리해석에 어긋나지 않고, 헌법이 하청근로자의 단체교섭권을 보장하는 취지를 고려하여 하청근로자의 근로조건에 관하여 실질적인 단체교섭이 가능할 수 있도록 하는 방안이”다(김민기, 앞의 논문 289쪽).

법의 규정만으로 직접 법규범으로서 효력을 발휘할 수 있는 구체적 권리이므로(대법원 2020. 9.3. 선고2016두32992 전원합의체 판결 참조), 교섭창구단일화 절차에 포섭될 수 있는지에 따라 노동조합법상 사용자의 개념이 달라진다고 해석하는 것은 본말이 전도된 것이다.”라고 판시한 바 있고,<sup>33)</sup> 2심 판결은 “단체교섭 및 단체협약체결 과정에 대하여는 구체적인 법률로 규율하지 않고 노사 간 자율적으로 정할 사항으로 남겨둘 수도 있는 것이므로(헌법재판소 2002. 12. 18. 선고 2002헌바12 결정 참조), 위와 같은 사용자 개념의 해석이 교섭창구단일화 절차 등 노동조합법이 규정하고 있는 단체교섭 절차 및 과정과 관련된 개별 규정들에 온전히 포섭되지 못하는 측면이 있다 하더라도 그러한 사정이 기본권으로서의 단체교섭권의 행사 범위를 제한할 근거가 되기는 어렵다.”라고 하여 창구단일화 절차의 존재를 이유로 원하청간 교섭을 거부할 수 없다는 취지를 밝혔다.

한편, 현대제철 및 한화오션 판결에서는 “원청이 하청 근로자의 근로조건을 실질적으로 지배·결정하는 부분에 관하여 하청 노동조합의 단체교섭 상대방이 된다고 하더라도, 원청의 사업을 기준으로 하는 교섭단위의 설정에 있어서는 노동조합법 위반이 있다고 보기 어렵다. 하청의 사업을 기준으로 기존 교섭단위 외에 교섭단위가 확대될 수 있으나, 다면적 노무제공관계를 통하여 복수의 사용자와 실질적인 노무제공 관계가 형성되어 있는 경우에는 구조적 실태를 반영하여 보다 탄력적이고 현실적인 교섭단위 설정이 인정될 필요가 있는바, 교섭단위의 확장이라는 절

33) 이러한 판결 취지는 현대제철 판결과 한화오션 판결에서도 나타난다. 즉, “노동조합법의 입법 목적과 교섭창구단일화 절차에 관한 노동조합법의 규정 내용에 비추어, 교섭창구단일화 제도는 근로자의 단체교섭권을 제한하기 위한 것이 아니라, 복수노조가 존재하는 동일한 교섭단위 내에서 교섭 상대방인 사용자에게 과도한 교섭 부담을 지우지 않기 위한 절차적 장치로 보아야 한다. 교섭창구단일화는 근로자 측의 조직 형태가 복수인 경우 사용자 측의 대응 가능성과 교섭 효율성을 고려한 절차 규정이지, 단체교섭권 자체를 제한하는 규범이라고 볼 수 없으므로, 교섭창구단일화 제도를 이유로 하여 실질적으로 사용자 지위에 있는 자와의 교섭 자체를 원천적으로 배제하는 것은 헌법에서 단체교섭권을 기본권으로 보장하고 있는 취지와 정면으로 충돌한다”.

차적 문제를 이유로 단체교섭권 자체의 실현을 저해하는 것이 타당하다고 할 수 없다”라고 하여 원청과 하청의 사업이 구분되는 것을 전제로 하청의 사업을 기준으로 교섭단위의 탄력적 설정이 필요함을 인정하였다.<sup>34)</sup>

정리하면, 앞선 사건들에서 법원이 일관되게 유지하고 있는 법리의 핵심은 교섭창구단일화라는 ‘절차적 기예’가 헌법상 보장된 ‘실체적 권리(단체교섭권)’를 침해하거나 부정하는 논거로 사용되어서는 안 된다고 볼 수 있다.

### 3. 필요설에 대한 비판적 검토

실질적 지배력이 인정된 사용자를 상대로 교섭을 요구하는 경우 창구 단일화 절차가 필요하다는 견해는 단일화의 단위를 어떻게 설정하느냐에 따라 다시 나뉘지만, 각 견해는 다음과 같은 문제점을 내포하고 있다.

#### 1) 원청 단위설에 대한 비판

원청 단위설은 원청과 하청 근로자 전체를 ‘하나의 사업’으로 보아, 하청 노조가 원청 정규직 노동조합 등을 포함한 모든 노동조합과 창구를 단일화해야 한다는 입장이다. 이는 결국 노조법상 사업의 개념을 ‘사업체계’의 개념으로 확장하는 것이다. 그러나 첫째, 이는 개정법의 문언인 “그 범위에 있어서는”과 정면으로 충돌한다. 개정법상 원청은 모든 근로조건이 아닌 실질적 지배력을 행사하는 특정 영역에 한정된 ‘부분적 사용자’에 불과하다. 반면, 창구단일화 제도는 교섭대표노동조합이 ‘모든’ 근로조건에 대한 포괄적 교섭권을 행사함을 전제로 한다. 책임의 범위가 서로 다른 이질적인 집단을 하나의 교섭 창구로 강제 통합하는 것은 제도 본질에 반한다.<sup>35)</sup> 둘째, 하청 근로자와 원청 근로자는 이해관계

34) 서울행정법원 2025. 10. 30. 선고 2024구합72896 판결(백화점·면세점 판매 서비스노동조합 사건)에서도 이러한 취지를 재차 확인할 수 있다.

35) 노동법에서 사용되는 사업의 개념은 이러한 책임의 범위와 밀접한 관련이 있다. 사업주는 사업을 지배하는 자이다. 이때의 지배는 자기 소속 근로자

가 상이하므로 이들을 하나의 단위로 묶는 것은 혼란만 가중할 것이다. 셋째, 하청업체의 독립된 사용자 지위를 부당하게 부정한다. 하청업체는 여전히 법률상 독자적인 사업주임에도, 원청 단위설은 이들의 교섭 당사자 적격 자체를 소멸시키는 결과를 초래할 수 있다. 넷째, 헌법상 단체교섭권을 형해화할 위험이 크다. 현실적으로 조합원 수에서 압도적 우위에 있는 원청 정규직 노동조합이 교섭대표권을 장악할 것이 명약관화하기 때문이다. 이 경우 이해관계가 전혀 다른 원청 노조가 하청 근로자의 근로조건을 좌우하게 되어, 정작 당사자인 하청 노동조합은 교섭 과정에서 철저히 배제될 수밖에 없다.<sup>36)37)</sup>

## 2) 하청 단위설에 대한 비판

하청 단위설은 하청업체 단위(개별 또는 전체)에서 먼저 교섭대표노동조합이 된 후에야 원청에게 교섭을 요구할 수 있다는 입장이다. 이 견해의 문제점은 첫째, 법의 목적과 절차가 모순된다는 점이다. 개정법의 취

---

의 모든 것에 ‘당연하게’ 미친다. 그래서 지배력 유무에 관한 판단기준 따위가 불필요하다. 부분적 사용자는 부분만을 지배하며, 부분적 지배는 자신의 지배영역 밖에 있는 근로자에 대해서만 개념적 성립이 가능할 뿐이다. 하여 그 범위가 모호하고 인정기준 또한 논란이 되는 것이다. 원청 단위설은 실질적 지배를 이러한 당연 지배와 구분하지 않는다.

36) 고용노동부의 2025.11.25.자 노조법 시행령 입법예고는 사업의 개념을 사업체계로 확장하는 것을 전제로 한다고 해석된다. 창구단일화절차를 이렇게 넓은 범위에서 어떻게 수행할지 일단 의문이 든다. 원청은 교섭요구를 받으면 교섭요구 사실의 공고를 해야하는데(노조법 시행령 제14조의3), 구체적으로 이를 어디에 할 것인지, 그리고 원청이 그러한 공고를 자신의 사업장 밖에 했다면 그 의미가 무엇인지가 당장 문제될 것이다. 그전에, 무엇보다 문제되는 것은 원청이 과연 협조할 것인가라는 부분이다(같은 취지 권오성, 앞의 글, 55쪽).

37) 법 개정 전후를 구분하여 창구단일화제도에 관한 해석론을 달리해야 한다는 견해(주31 참조)가 있으나 창구단일화제도의 적용 단위인 ‘하나의 사업 또는 사업장’ 개념에 변경이 없는 점, 사용자 개념의 확장이 사업 개념의 확장과 논리필연적으로 연결되지 않는 점에서 수긍하기가 어렵다. 그럼에도 개정법하에서 창구단일화제도를 적용하고자 한다면, 특히 원청을 중심으로 단일화를 하고자 한다면 입법을 통해 ‘사업’보다 상위 개념, 예컨대 ‘사업체계’와 같은 개념을 교섭단위로 채택해야 할 것이다.

지는 하청업체에게는 실질적 권한이 없으므로 원청과 직접 교섭하라는 것이다. 그러나 하청 단위설은 “원청과 교섭하기 위해, 먼저 실질적 권한이 없는 하청업체 단위에서 대표 자격을 획득하라”고 요구하는 셈이 되어 논리적 모순에 빠진다. 둘째, 현실적으로 사용자가 어용노조 설립 등을 통해 교섭대표 지위를 선점함으로써 하청 노동조합의 원청 교섭 요구 자체를 원천 봉쇄할 가능성도 배제할 수 없다. 셋째, 세부적으로 보더라도, 무수한 하청업체를 하나의 단위로 묶는 ‘전체 하청 단위설’은 서로 다른 업종과 이해관계를 가진 노조들을 무리하게 통합하여 오히려 교섭 혼란을 가중시킬 것이다. 반면 ‘개별 하청 단위설’은 기업의 울타리를 넘어서려는 개정법의 초기업적 교섭 취지를 다시 개별 기업 단위로 회귀시킨다는 문제가 있다.

#### 4. 소결

헌법상 기본권 보장의 원칙과 현행법의 문언, 그리고 최근 법원의 일관된 판결 논리를 종합적으로 고려할 때, 원하청 교섭에 있어서는 기존의 창구단일화 절차가 적용되지 않는다는 불요설이 가장 타당한 해석론이라 할 것이다. 구체적으로 살펴보자.

첫째, 기본권 최대 보장의 원칙과 창구단일화 규정의 문언 해석에 부합한다. 단체교섭권은 헌법이 보장하는 근로자의 기본권이며, 이를 제한하는 규정은 엄격하게 해석되어야 한다. 노조법 제29조의2 제1항은 창구단일화의 요건으로 “하나의 사업 또는 사업장”을 명시하고 있는데, 특별한 사정이 없는 한 사업의 개념은 법인을 단위로 이해하는 실무적 견지에서 원청과 하청은 법률적·사실적으로 별개의 사업장이다.<sup>38)39)</sup> 따라서

38) 예컨대, 구 근로기준법상 퇴직금제도 차등 설정을 금지하는 단위로서의 사업의 개념에 대하여 “‘사업’이란 특별한 사정이 없는 한 경영상의 일체를 이루는 기업체 그 자체를 의미한다”(대법원 1999. 8. 20. 선고 98다765 판결 등)는 판결 참조. 학교법인과 부속병원을 하나의 사업으로 본 사례이다.

39) 필요설 중 원청단위설은 원청의 사업의 범위를 하청단위로까지 확장하는데, 이는 마치 원재료 공급에서 최종 생산 및 유통을 아우르는 공급망 전체를 원청의 사업이라고 보는 것과 같다. 사업은 책임의 범위를 뜻하는 것으로



동 조항을 유추·확장 해석하여 독립된 사업주인 하청 노동조합을 원청의 교섭 창구에 강제로 편입시키는 것은 근로자에게 불이익을 주기 위한 기본권 침해적 해석이다.<sup>40)</sup>

둘째, 법원의 일관된 지지이다. 비록 대법원의 확립된 판례는 아직 존재하지 않으나, 다수의 하급심 판결은 원하청 교섭에서 절차적 장애가 실제적 권리를 부정할 수 없다는 원칙을 분명히 하고 있다. 법원은 사용자가 “창구단일화 절차 이행의 현실적 곤란함”을 들어 교섭을 거부한 데 대하여, 앞에서 본 바와 같이 일관되게 교섭거부의 정당성을 인정하고 있지 않다. 이러한 사법부의 태도는 현행 창구단일화 절차가 개정 노조법 하에서는 원하청 관계에 그대로 적용되기 어렵다는 현실을 인정한 것이자, 절차보다는 권리의 실질적 보장이 우선되어야 한다는 불요설의 입장을 강력하게 뒷받침한다.

셋째, 제도 도입 취지와와의 부조화이다. 창구단일화 제도는 교섭의 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 도입되었다. 그러나 이해관계가 근본적으로 상이한 원청 정규직 노조와 하청 노조를 하나의 창구로 강제 통합하는 것은 오히려 극심한 노노 갈등과 교섭 지연을 초래하여 제도의 본래 목적인 효율성마저 저해할 것이다.

---

현행법 해석상 공급망 단위까지 확장하는 개념으로 인정된 예는 찾아보기 어렵다. 생각건대, 앞에서 세 가지 기준을 제시하면서 언급한 “사업체계”라는 개념(주18 참조)이 공급망적 견지에서 편입을 논할 때 사용될 수 있을 것이다. 요컨대 범위의 크기를 비교하면 사업체계 > 사업(또는 사업장)이다. 이러한 개념 정의에 따르면, 원청단위설은 창구단일화를 해야 하는 범위를 통상의 사업에서 ‘사업체계’로까지 확장하는 견해라고 볼 수 있다. 우리 노조법이 전혀 예정하고 있지 않은 범위를 설정한 것이다.

- 40) 이와 관련하여 “최근에는 법인격(기업)을 뛰어넘어 노동력 제공의 수직적 연계(이른바 공급사슬망)가 형성되어 있는 경우, 이 연계망 전체를 하나의 사업으로 포섭하여 노동의 보호를 도모할 필요성이 있을 수 있다.”는 지적을 하여 볼 필요가 있다(이철수, 『노동법』 개정판, 현암사, 2025, 74쪽; 밑줄은 필자). 노동보호의 관점에서 사업의 다양한 표현 양식을 포착할 필요가 있다는 “동태적 사업 개념”에 대해서는 박제성, 『동태적 사업 개념 - 노동법상 사업 개념의 재검토』, 한국노동연구원, 2022 참조. 사업의 개념을 법인 밖으로 확장하여 인정함으로써 근로자 보호를 강화한 사례로 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023두57876 판결.

넷째, ‘교섭 혼란’ 우려의 비현실성과 노사 자치이다. 경영계는 자율교섭이 인정되면 다수의 하청 노조가 난립하여 교섭 혼란이 발생할 것이라 우려하나, 현재 하청 노동조합의 낮은 조직률을 고려할 때 과장된 측면이 있다. 설령 복수 노조가 존재하더라도, 이는 노동조합이 산별노조 체제로의 전환이나 공동교섭단 구성 등을 통해 자율적으로 해결해야 할 영역이다. 국가는 노사 자치 역량을 신뢰하고 그들이 선택한 권리 행사의 방법을 존중해야 한다. 과거와 같이 혼란을 예단하여 후견주의적 입장에서 개입·억제해서는 안 된다.

## 5. 향후의 과제

원하청 교섭에서 창구단일화 절차가 적용되지 않는다는 ‘불요설’이 현재의 법제하에서는 법리적으로 가장 타당한 해석론이다. 다만, 법제도 자체의 불완전성으로 인해 이를 실무에 적용함에 있어서는 다음과 같이 몇 가지 해결해야 할 현실적인 과제가 존재한다.

첫째, 다수 하청 노조의 산발적 교섭 요구 가능성이다. ‘이론적으로’ 수많은 하청업체의 노동조합들이 각기 다른 시기에 원청에게 교섭을 요구할 수 있어, 원청 사용자가 연중 상시적인 교섭 상태에 놓이게 될 우려가 있다. 비록 현재 하청 노조의 조직률이 낮고 그들 스스로 최선의 합리적 교섭전략을 선택할 것이라는 기대를 고려할 때 그 가능성은 낮지만, 잠재적인 혼란의 불씨는 남아 있다.

둘째, 경쟁하는 하청 노조 간의 소통창구 부재이다. 만약 동일한 원청을 상대로 상급단체를 달리하는 복수의 하청 노동조합(예컨대, 민주노총 소속 노조와 한국노총 소속 노조)이 동시에 교섭을 요구할 경우, 이들 사이의 교섭권을 조정할 법적 장치가 부재하다는 입법의 공백이 발생한다. 이는 자칫 사용자에게 개별 교섭을 통한 각개격파나 노노 갈등을 유발할 빌미를 제공할 수 있다.

그러나 이러한 실무상 어려움에도 불구하고 ‘불요설’을 기초로 고민해야 하는 이유는 명백하다. 그것이 다음과 같이 현재의 법상태에서는 헌법상 노동기본권의 본질을 지키는 최선의 길이기 때문이다. 첫째, 앞서

살펴보았듯 ‘필요설’은 필연적으로 하청 근로자의 교섭권을 형해화하거나(원청 단위설) 원천 봉쇄하는(하청 단위설) 결과를 초래한다. 불요설만이 하청 근로자가 자신의 노동조건을 현실적으로 지배하는 사용자와 대등하게 대화할 수 있는 권리를 ‘실질적으로’ 보장한다. 둘째, 노동조합의 자주성과 단결 선택권을 존중한다. 국가는 행정적 편의를 위해 이해관계가 다른 집단을 강제로 통합해서는 안 된다.<sup>41)</sup> 근로자들이 스스로 선택한 단결의 형태와 교섭 방식을 존중하는 것이 헌법 정신에 부합한다.<sup>42)</sup> 셋째, 헌법상 기본권 우위의 원칙 확인이다. 절차적 효율성이나 관리의 편의를 위해 기본권의 본질적인 내용을 침해하는 것은 주객이 전도된 것이다. 설령 실무적인 혼란이나 비용이 발생하더라도, 이를 감수하고 기본권을 보장하는 것이 국가의 1차적 책무임을 재확인해야 한다. 실무적 난점은 노사의 자율적 노력과 정부의 합리적 조력을 통해 극복해 나가야 할 과제이지, 권리 자체를 부정할 명분이 될 수는 없다.

불요설이 모든 문제를 해결하는 만능열쇠는 아니다. 입법이 정비되지

41) 시행령 개정안(주36 참조)은 교섭단위를 합친 후 다시 분리하는 방안을 제안한다. 그런데 분리는 통합을 전제하므로 국가가 통합을 강제하겠다는 취지를 내포한다. 시행령 개정안에 대한 평가는 추후 실제 시행되면 이루어지겠지만, 당장 국가의 개입에 대해 노사로부터 신뢰를 담보할 수 있는지 혹은 신뢰 담보를 위한 방안은 무엇인지, 절차상 새로운 난점과 혼란이 발생할 가능성이 있는데 적절한 해법이 있는지, 무엇보다 단체교섭권 침해의 소지가 다분한 창구단일화제도를 강제한다는 점에서 노동기본권 침해를 완화할 수 있는지 등과 관련한 논란이 예상된다.

42) 권오성 교수는 불요설과, 하청단위설은 서로 배척하는 것이 아니라 하청노조가 선택할 사항으로 본다. “하청노조가 ‘규범적으로는 하청기업에게 처분권한이 있으나 원청기업도 처분권한을 사실상 행사해 온 사항’에 대해 하청기업과 원청기업 모두를 단체교섭의 상대방으로 하여금 교섭을 요청한 경우에는 (하청단위설)의 해석에 따라 해당 하청기업을 교섭단위로 해서 교섭창구단일화를 거쳐야 한다고 해석하는 것이 합리적이다. 반면, 하청노조가 원청기업의 사업장 내 위협원에 대한 처리 등에 대해서 원청기업만을 상대로 해서 단체교섭을 요구한 경우에는 하청노조가 원청기업만을 상대로 단체교섭을 요구하는 것은 당초 교섭창구단일화 제도가 예상한 교섭방식이 아니므로 교섭창구단일화를 거칠 필요가 없다고 해석함이 상당하다.”(권오성, 앞의 글, 55쪽). 사건으로 불요설이 최선이나 차선으로는 개별 하청단위설을 지지한다.

않은 현 법제 하에서의 최선일 뿐이다. 앞서 지적한 실무적 난점들은 여전히 유효한바, 불요설의 채택은 끝이 아니라 새로운 교섭 질서 구축을 위한 시작점에 불과하다.

#### IV. 새로운 교섭 질서 구축을 위한 노사정의 과제

개정 노조법 시대의 안정적인 노사관계는 법원의 해석만으로는 달성될 수 없으며, 노사정 각 주체의 능동적인 관점 전환과 역할 분담이 필수이다.

첫째, 노동조합은 ‘분산’된 교섭 요구가 야기할 수 있는 혼란을 스스로 극복하기 위해 ‘자율적이고 전략적인 단결’을 모색해야 한다. 개별 기업의 울타리를 넘어 원청 단위의 산별 지부·지회로 단결하거나, 상급단체가 다르더라도 ‘공동교섭단’을 구성하여 원청에 통일된 목소리를 전달하는 노력이 필요하다. 또한, 교섭 초기 단계에서 불필요한 범위 분쟁을 최소화하기 위해 핵심 의제에 집중하는 전략적 접근이 요구된다.

둘째, 원청 사용자는 교섭 회피라는 ‘수동적 방어’ 전략에서 벗어나, 새로운 교섭 질서를 ‘선제적으로 설계’하는 전향적 자세로 전환해야 한다. 원하청 교섭을 단순한 비용 요인이 아닌 공급망 리스크 관리의 기회로 인식하고, 노조의 자율적 단일화 시도를 적극 수용함으로써 교섭 효율성을 높여야 한다. 나아가 협약의 실질적 이행을 담보하기 위해 하청 업체를 포함한 ‘3자 교섭 모델’을 역제안하는 등 주도적으로 새로운 관행을 만들어갈 필요가 있다.

셋째, 정부는 규제 중심의 행정에서 벗어나 노사 자치를 지원하는 ‘조력자’이자 ‘촉진자’로 거듭나야 한다. 기계적인 창구단일화를 강제하려는 시도는 지양해야 한다. 대신 노동위원회의 조정 기능을 확대하여 노조의 자율적인 공동교섭단 구성을 지원하고, 다양한 산업 현장에 적합한 ‘모범 교섭 모델(Best Practice)’을 연구·보급함으로써 법 제도의 공백을 합리적인 행정 서비스로 메워야 할 것이다.

## V. 나가며

제조물 책임 법리가 초기 ‘매수인 위험 부담’이라는 형식적 계약 원칙에서 출발하여, 소비자의 ‘입증 부담을 완화’하는 과실 책임을 거쳐, 오늘날 ‘무과실 책임’으로 발전해 온 역사는 노동법학에도 시사하는 바가 크다. 이는 법이 현실의 힘의 불균형을 시정하고 실질적 정의를 구현하기 위해 끊임없이 진화해 왔음을 보여주는 증거이다.

개정 노조법 제2조는 노동관계법령에서 이러한 진화가 비로소 시작되었음을 알리는 신호탄이다. 하청 근로자들은 이제 형식적인 계약의 장벽을 넘어 자신들의 근로조건을 실질적으로 결정하는 ‘진짜 사장’과 대화할 수 있는 법적 근거를 명시적으로 가지게 되었다. 그러나 이는 제조물 책임의 역사에 비추어 볼 때, 이제 막 ‘과실 책임’의 단계로 진입한 것에 불과하며 여전히 넘어야 할 산이 많다.

특히 이 글에서는 다루지 못하였으나, ‘실질적 지배력’의 입증책임 문제 역시 간과되어서는 안 될 중요 과제이다.<sup>43)</sup> 정보의 편재가 심각한 현대 기업구조 하에서 전통적인 입증책임 원칙만을 고수한다면 개정법은 자칫 사문화될 위험이 크기 때문에, ‘사실상의 추정’ 등 해석론적 보완을 통해 입증 부담을 합리적으로 완화하려는 노력이 반드시 수반되어야 한다.

결국 개정법의 성패는 법문 그 자체보다 이를 운용하는 우리의 의지와 역량에 달려 있다. 노사정 3주체의 성숙한 역할 분담을 통해 새로운 교섭 질서를 구축해 나가야 한다. 노동의 영역에서도 “실질적 권한이 있는 곳에 책임이 있다”는 상식이 온전히 뿌리내릴 때까지, 법의 해석과 현실의 관행은 계속해서 진화해야 할 것이다.

주제어: 개정 노동조합법, 노란봉투법, 실질적 지배력, 사용자성, 원하청교섭, 교섭창구단일화

43) 필자의 견해에 대한 개괄적 소개는 줄고, “개정 노동조합법 제2조 시행의 쟁점과 과제”, 『한국고용노사관계학회 2025년 추계 정책토론회 자료집』, 2025. 10. 30. 14-17쪽 참조.

## 참고문헌

- 이철수, 『노동법』 개정판, 현암사, 2025.
- 박제성, 『동태적 사업 개념: 노동법상 사업 개념의 재검토』, 한국노동연구원, 2022.
- 김홍영·권오성·김린·노호창·방강수, 『노동분쟁에서 당사자 적격의 판단기준에 관한 연구』, 중앙노동위원회 연구용역보고서, 2020.
- 윤진수, 『민법논고 VI』, 박영사, 2015.
- 강성태, “사내하도급 삼부작 판결의 의의”, 『노동법학』 제35호, 한국노동법학회, 2010.
- 고수현, “아사히방송 판결 이후”, 『법학논총』 제40집 제4호, 한양대학교 법학연구소, 2023.
- 권오성, “하청노조의 단체교섭에 관한 쟁점”, 『노동법률』 2021년 6월호, 중앙경제사.
- 김 린, “화물자동차 안전운임제에 대한 법적 평가와 과제: 헌법상 적정임금 보장의 관점에서”, 『법학연구』 제28집 제3호, 인하대학교 법학연구소, 2025.
- 김 린, “개정 노동조합법 제2조 시행의 쟁점과 과제”, 『한국고용노사관계학회 2025년 추계 정책토론회 자료집』, 2025.
- 김민기, 『사내하청에 대한 노동법적 규율 - 단체교섭권의 실현을 중심으로 -』, 서울대학교 법학박사 학위논문, 2023.
- 김홍영·강주리, “택배회사를 대리점 택배기사에 대해 단체교섭의무를 지는 사용자로 인정한 중앙노동위원회 판정의 의미”, 『노동법연구』 제51호, 서울대노동법연구회, 2021.
- 박수근·장영석, “원청사업주의 단체교섭의무와 실질적 지배력 판단기준 및 교섭 사항”, 『노동법학』 제92호, 한국노동법학회, 2024.
- 이승욱, “다면적 노무제공관계에서 부분적·중첩적 사용자성 - 중앙노동위원회 결정의 의의와 과제 -”, 『노동법학』 제80호, 한국노동법학회, 2021.
- 이승욱, “노동조합법 제2·3조 개정의 쟁점과 향후 과제 - 미국과의 비교를 중심으로 -”, 『노동법학』 제95호, 한국노동법학회, 2025.
- 이정훈, “원청사업주의 실질적 지배력 판단지표”, 『노동법연구』 제54호, 서울대학교 노동법연구회, 2023.
- 이태현, “미국 공동사용자 법리의 현황과 시사점: 브라우닝 펠리스 결정과 그 이

후의 전개를 중심으로”, 『노동법학』 제86호, 한국노동법학회, 2023.

장영석, “간접고용과 교섭창구단일화 절차”, 『노동법학』 제73호, 한국노동법학회, 2020.

최민용, “모자회사와 기업지배구조”, 『기업법연구』 제32권 제3호, 한국기업법학회, 2018.

<Abstract>

A Study on the Standards for Determining  
Substantial Control and Collective Bargaining  
Procedures under the Revised TULRAA

KIM, Lin\*

The recent amendment to Article 2 of the Trade Union and Labor Relations Adjustment Act (“TULRAA”) expands the definition of “employer” to reflect the reality of multi-layered labor structures. By codifying the principle that “responsibility lies where substantial power exists.” the amendment imposes collective bargaining obligations on principal contractors who exercise substantial and specific control (“SSC”) over subcontracted workers' conditions, even in the absence of direct employment agreements.

This paper critically examines the interpretation of SSC and the applicability of the “single bargaining window” procedure. It argues that existing judicial criteria are often circular or conflated with indicators of illegal dispatch. To address this, the paper proposes three distinct criteria for determining employer status: (1) structural control over the determination of working conditions (e.g., determination of the labor cost budget), (2) organizational incorporation or systemic control through business processes (e.g., supply chain management systems), and (3) substantial status as a bargaining party capable of practically resolving disputes.

Furthermore, the paper addresses the procedural controversy regarding the “single bargaining unit rule” It supports the “No Necessity of the

---

\* Professor of INHA School of Law.



procedure” arguing that requiring subcontracted unions to unify bargaining channels with the principal’s regular employees or other subcontractors is logically inconsistent and infringes upon the constitutional right to collective bargaining. The paper concludes that establishing a new bargaining order requires recognizing the principal contractor as a “partial employer” within the scope of their control, thereby ensuring practical relief and substantive bargaining rights for subcontracted workers.

Key Words: Revised Trade Union Act, Yellow Envelope Law,  
Substantial Control, Collective Bargaining, Single  
Bargaining Unit Rule